

Ausgewählte Rechtsfragen in der (Sport-)Medizin

Das Arzt- und Medizinrecht besteht aus vielfältigen Aspekten. Es würde den Rahmen der Darstellung innerhalb eines Buchkapitels sprengen, auf alle Einzelheiten dieser Materie einzugehen (siehe weiterführende Literatur: Bergmann et al. 2012, Dettmeyer 2006, Eickhoff und Fenger 2004, Laufs und Uhlenbruck 2010, Laux et al. 2012, Laux et al. 2013a, 2013b, Martis und Winkhart 2014, Neelmeier 2014, Parzeller 2002a, Parzeller 2003, Parzeller und Zedler 2011, 2013a, 2013b, 2014, Pauly und Parzeller 2004, Quaas und Zuck 2014, Ratzel und Lippert 2010, Ratzel und Luxenburger 2011, Ries et al. 2004, Rieger et al. 2014, Spickhoff 2011, Steinbeck und Fenger 2004, Tolup et al. 2014, Ulsenheimer 2015, Wenzel 2012).

Der Schwerpunkt der nachfolgenden Darstellung befasst sich mit der gerichtlichen **Wertung ärztlicher Sorgfaltspflichten** bei der Behandlung von Patienten und Sportlern (Aufklärung, Einwilligung, Behandlungsfehler, Doping etc.) und dem **Schutz der höchstpersönlichen Patientendaten** (Dokumentation, Schweigepflicht, Einsichtnahme durch den Patienten). Dabei wird auf ausgewählte neue gesetzliche Vorgaben des Patientenrechtegesetzes (PatRG) eingegangen, das seit dem 26.2.2013 in Kraft getreten ist. Ebenfalls erfolgt eine kurze Darstellung möglicher neuer Vorgaben in der staatlichen Dopingbekämpfung, die sich aus dem derzeit vorliegenden Gesetzentwurf eines Anti-Doping-Gesetzes ergeben (Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 27.3.2015 – BR-Drs. 126/15). Da es sich bei dem PatRG und den Dopinggesetzen um neue Regelungen handelt, die der weiteren Interpretation durch Rechtsprechung und Wissenschaft unterliegen, kann der vorliegende Beitrag im konkreten Einzelfall eine juristische Beratung, z. B. durch die Rechtsabteilungen der Landesärztekammern oder einen Fachanwalt für Medizinrecht, nicht ersetzen.

Berücksichtigt wurde der Gesetzes- und Meinungsstand bis April 2015.

Schließlich soll auf die wesentlichen versicherungsrechtlichen Aspekte im Rahmen des Sportrechts eingegangen werden. Die Erläuterungen orientieren sich an den gängigen Versicherungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Deckungskonstellationen.

90.1 Allgemeine rechtliche Bewertung des ärztlichen Heileingriffs

Markus Parzeller

Ohne Übergangsfrist trat am 26.2.2013 das PatRG (Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten) in Kraft (ausführliche Erläuterungen mit weiteren Nachweisen bei Hoffmann et al. 2014, Parzeller und Zedler 2013a, 2013b, 2014, Parzeller et al. 2014, Spickhoff 2013). Mit diesem Artikelgesetz wurde das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB V), die Patientenbeteiligungsverordnung, das Krankenhausfinanzierungsgesetz, die Zulassungsverordnung für Vertragsärzte, die Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte und die Bundesärzteordnung geändert. In das Zivilrecht wurden beim Recht der Schuldverhältnisse der Behandlungsvertrag in den §§ 630a–h BGB neu eingefügt:

- § 630a BGB. Vertragstypische Pflichten beim Behandlungsvertrag
- § 630b BGB Anwendbare Vorschriften
- § 630c BGB Mitwirkung der Vertragsparteien; Informationspflichten
- § 630d BGB Einwilligung
- § 630e BGB Aufklärungspflichten
- § 630f BGB Dokumentation der Behandlung
- § 630g BGB Einsichtnahme in die Patientenakte

- § 630h BGB Beweislast bei Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler

Mit dem Gesetz wollte der Gesetzgeber (BR-Drs. 312/12 S. 1, 9; BT-Drs. 17/10488 S. 1) die Patientenrechte verbessern, das Behandlungs- und Arzthaftungsrecht stärker bündeln und Vollzugsdefizite beseitigen. Ein mündiger Patient sollte gegenüber dem Leistungserbringer und -träger in seinen Rechten gestärkt werden. Neben der Fehlervermeidung erhoffte sich der Gesetzgeber eine Signalwirkung und Verbesserungen bei der Patientenbeteiligung und -information.

Regelmäßig schuldet der Arzt dem Patienten wie dem verletzten Sportler nur die ordnungsgemäße, **lege artis durchgeführte medizinische Behandlung** (vgl. § 630a Abs. 2 BGB stellt auf den zum Zeitpunkt der Behandlung bestehenden, allgemein anerkannten fachlichen Standard ab), da er für den Erfolg der ärztlichen Heilbehandlung nicht garantieren kann (Ausnahme, wenn ausdrücklich ein Werkvertrag vereinbart ist, z. B. bzgl. Herstellung einer passenden Prothese). In den letzten Jahren hat die Anzahl der Verfahren gegen Ärzte wegen bloß behaupteter oder tatsächlich vorliegender Behandlungsfehler – in der Öffentlichkeit als „**Kunstfehler**“ bezeichnet – drastisch zugenommen (Fleuth et al. 2014; siehe z. B. auch Urteilsanalyse zivilrechtlicher Verfahren des LG Kassel und des LG Marburg bei Knaak und Parzeller 2014).

Seit der Entscheidung des Reichsgerichts vom 31.5.1894 (RGSt 25, 375 ff.) wertet die höchstrichterliche Rechtsprechung auch des Bundesgerichtshofs (BGH) den **ärztlichen Heileingriff tatbestandlich als Körperverletzung im Sinne der §§ 223 ff. StGB** (siehe Übernahme der rigorosen Ansicht durch BGH vgl. auch im Zivilrecht: BGHZ 29, 46 ff.). Eine Strafbarkeit kommt üblicherweise nicht in Betracht, wenn der Eingriff durch eine (mutmaßliche) **Einwilligung des Patienten nach Aufklärung durch den Arzt gerechtfertigt** ist (vgl. BGH NStZ 2004, 442 zur Täuschung über Operationsindikation und fehlender Einwilligung).

Aus den Urteilgründen des RG: „Daß jemand nach eigener Überzeugung oder nach dem Urteile seiner Berufsgenossen die Fähigkeit besitzt, das wahre Interesse des Nächsten besser zu verstehen, als dieser selbst, dessen körperliches oder geistiges Wohl durch geschickt und intelligent angewendete

Mittel vernünftiger fördern zu können, als dieser es vermag, gewährt jenem nicht irgend eine rechtliche Befugnis, nunmehr nach eigenem Ermessen in die Rechtssphäre des Anderen einzugreifen, diesem Gewalt anzutun und dessen Körper willkürlich zum Gegenstand gut gemeinter Heilversuche zu benutzen ... Strafrechtlich hat der Angeklagte normwidrig gehandelt und ein nach § 223 StGB zu ahndendes Delikt verübt.“

§ 223 StGB (Strafgesetzbuch): Körperverletzung

(1) Wer eine andere Person körperlich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

90.2 Aufklärung und Einwilligung

Markus Parzeller

Das **Selbstbestimmungsrecht** des Patienten, in jeder Phase der Behandlung über den Eingriff in seine körperliche Integrität zu entscheiden, ist verfassungsrechtlich verbürgt. In § 630d BGB ist die Einwilligung im Rahmen des Behandlungsvertrags geregelt.

Das Bundesverfassungsgericht stellt unmissverständlich fest: „Die Beachtung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten ist wesentlicher Teil des ärztlichen Aufgabenbereichs“ (BVerfG VersR 1979, 907) und „der Anspruch des Patienten auf Unterrichtung über Befunde und Prognosen ist Ausdruck des durch grundrechtliche Wertungen geprägten Selbstbestimmungsrechts und der personalen Würde des Patienten“ (BVerfG Beschl. v. 18.11.2004–1 BvR 2315/04).

Nach Ansicht des BGH (BGHSt 12, 379, Urteil vom 10.2.1959–5 StR 533/58– Anl. N 8) ist die Rolle der Einwilligung des Kranken sowie die Sorgfalt, mit der ein Arzt bei der Einholung dieser Einwilligung verfährt und mit der er sich über ihr Vorliegen, ihre Wirksamkeit und ihren Umfang vergewissern muss, von entscheidender Bedeutung.

Der BGH stellte klar (BGH VersR 1989, 851; grundlegend BGHZ 29, 46), dass das **Erfordernis einer Einwilligung** des Patienten in die ärztliche Heilbehandlung zur Rechtfertigung des Eingriffs in die körperliche Integrität

- aus dem Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG),
- aus dem Selbstbestimmungsrecht als Ausfluss des Rechts auf Menschenwürde (Art. 1 GG) und
- aus der Entscheidungsfreiheit des Patienten herrührt.

„Fehlt die wirksame Einwilligung, ist der in der ärztlichen Heilbehandlung liegende Eingriff in die körperliche Integrität des Patienten rechtswidrig.“

Nach § 630d BGB (siehe BR-Drs. 312/12 S. 32; BT-Drs. 17/10488 S. 23; Parzeller und Zedler 2013b) besteht die Verpflichtung des Behandelnden zur Einholung der Einwilligung vor Durchführung der medizinischen Maßnahme. Sie ist durch den Patienten oder bei einem einwilligungsunfähigen Patienten (z. B. Kleinkind) durch den Berechtigten (z. B. Betreuer, Eltern) zu erteilen (Ausnahme: Vorgaben in einer Patientenverfügung). Als Ausnahme von dieser Verpflichtung zur Einholung der Einwilligung können unaufschiebbare Maßnahmen, z. B. bei komatösem Unfallopfer, in Betracht kommen, wobei dann der mutmaßliche Wille des Patienten maßgeblich ist (§ 630d Abs. 1 S. 4 BGB). Eine Wirksamkeitsvoraussetzung der Einwilligung ist eine ordnungsgemäße Aufklärung gemäß § 630e Abs. 1–4 BGB. Ohne Aufklärung kann es zu einer Verletzung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten kommen, was eine Pflichtverletzung gemäß § 280 Abs. 1 BGB darstellen kann. Der Patient kann seine Einwilligung jederzeit, formlos und ohne Angaben von Gründen widerrufen.

Die ärztliche Aufklärungspflicht hat für die Einwilligung als Rechtfertigung für das ärztliche Handeln zentrale Bedeutung (§ 630d Abs. 2 BGB; Parzeller et al. 2009, Parzeller und Zedler 2013b). Der Gesetzgeber hat die Aufklärung inzwischen durch das Patientenrechtegesetz in § 630e BGB allgemein gesetzlich geregelt. Es finden sich zudem zahlreiche **spezialgesetzliche Bestimmungen über die ärztliche Aufklärung**, z. B. im Transplantationsgesetz

oder den entsprechenden Berufs- und Standesordnungen. Bei der Aufklärung wird zwischen der Selbstbestimmungsaufklärung oder Eingriffsaufklärung (§ 630e BGB) und den Informationspflichten (§ 630c BGB; früher auch therapeutische Aufklärung oder Sicherheitsaufklärung) unterschieden:

- Die **Selbstbestimmungsaufklärung bzw. Eingriffs- oder Grundaufklärung** soll den Patienten für eine freie und selbstverantwortliche Entscheidung im Großen und Ganzen informieren, um in den ärztlichen Eingriff einwilligen zu können. Als ärztlicher Eingriff ist jede ärztliche Maßnahme in die körperliche Integrität des Patienten zu werten (z. B. Operationen, Schmerztherapie, Medikamentengabe etc.). Sie wird (BGH, Beschluss v. 16.11.2004 – VI ZR 28/04) in folgende Formen unterteilt:
 - Diagnoseaufklärung (Information über Befunde und Erkrankung; ggf. Einschränkungen bei finalen und infausten Erkrankungen)
 - Verlaufsaufklärung (Information über Art und Weise, praktische Durchführung und Verlauf des Eingriffs, Erfolgsaussichten)
 - Risikoaufklärung (vgl. auch BGH Ur. v. 10.10.2006 – VI ZR 74/05; BGH, VersR 2005, 835 ff. zur Risikoaufklärung einer medikamentösen Therapie).

Nach § 630e BGB ist der Patient über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären, wobei die Auflistung nach dem Willen des Gesetzgebers (BR-Drs. 312/12 S. 34; BT-Drs. 17/10488 S. 24) nicht abschließend ist:

- Art und Umfang der Maßnahme
- Durchführung der Maßnahme
- Folgen und Risiken der Maßnahme
- Notwendigkeit der Maßnahme
- Dringlichkeit der Maßnahme
- Eignung der Maßnahme
- Erfolgsaussichten im Hinblick auf Diagnose und Therapie

Dem Patienten soll zwar kein „medizinisches Detailwissen“ (BR-Drs. 312/12 S. 34; BT-Drs. 17/10488 S. 24) vermittelt werden, aber der Patient muss für die konkrete Behandlungssituation über Schwere und Tragweite des Eingriffs, insbesondere Art und Weise, Umfang und Intensität in laienverständlicher Weise unterrichtet werden (ausführlich: Parzeller et al. 2009, Parzeller und Zedler 2013b).

Nach § 630e Abs. 1 S. 3 BGB ist über Behandlungsalternativen aufzuklären, wenn diese gleichermaßen indiziert sind und sich hinsichtlich der Belastungen, der Risiken und der Heilungschancen unterscheiden. Zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten ist dieser deshalb über **alternative Behandlungsmethoden** zu unterrichten (so bereits: BGH VersR 1982, 771; 1984, 470; 1988, 179 ff.; BGH Urt. v. 15.3.2005 – VI ZR 313/03; OLG Braunschweig, NJOZ 2008 48 ff.), wenn die zur Verfügung stehenden medizinisch sinnvollen und indizierten Verfahren z. B.

- zu unterschiedlichen Belastungen des Patienten führen,
- unterschiedliche Risiken und Erfolgchancen beinhalten,
- dem Patienten eine echte Wahlmöglichkeit bieten.

Der BGH (VersR 2000, 766) hat bei einer **relativen Operationsindikation** festgestellt, dass der Patient über die **Möglichkeit einer konservativen Therapie** aufzuklären ist, wenn damit die Operation vermieden werden kann.

Die Aufklärung kann auch durch einen Arzt durchgeführt werden, **der den Eingriff nicht selbst durchführt**. Dies setzt voraus, dass die ordnungsgemäße Durchführung durch den nachgeordneten Arzt sichergestellt ist und die Aufklärung ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt wird (vgl. BGH Urt. v. 7.11.2006 – VI ZR 206/05). Nach der Rechtsprechung des BGH (VersR 1981, 456 f.) kann auch dieser zum Ersatz des durch die Operation entstandenen Körperschadens verpflichtet sein, wenn die Aufklärung unvollständig und daher die Einwilligung des Patienten unwirksam war. Der aufklärende Arzt übernimmt durch sein Tätigwerden nämlich einen Teil der ärztlichen Behandlung des Patienten.

Für die Durchführung der Aufklärung gelten folgende Vorgaben (BR-Drs. 312/12 S. 35; BT-Drs. 17/10488 S. 24 f.) für den aufklärenden Personenkreis (Behandelnder oder andere Person mit für die Durchführung der Maßnahme notwendigen Ausbildung):

- Mündlich (ergänzende Bezugnahme auf Unterlagen [in Textform] möglich)
- Verständlich (Problem: ausländischer Patient [Wienke und Sailer 2013])

- Rechtzeitig vor Beginn der Behandlung
 - Ausreichende Zeit des Patienten zur Überlegung
 - Zur Wahrung des Selbstbestimmungsrechts in angemessener Weise
 - Keine pauschale Festlegung bestimmter Fristen
 - Unterschiedliche Fristen im konkreten Einzelfall
 - Mögliche („Regel“-)Beispiele des Gesetzgebers
 - bei operativen Eingriff: am Vortag des Eingriffs ausreichend
 - bei eiligem Eingriff: am Tag des Eingriffs ausreichend („Verkürzte Bedenkzeit“)
 - halbe Stunde zwischen Narkose und Eingriff: nicht ausreichend

Im konkreten Einzelfall ist daher kritisch zu prüfen, ob das Selbstbestimmungsrecht des Patienten gewahrt ist, wobei bei Eilbedürftigkeit die Zeitspanne zwischen Aufklärung verkürzt und bei einem elektiven Eingriff verlängert sein dürfte. Bei **lebensbedrohlichen Sportverletzungen** sind die **Anforderungen an die Einwilligung des verletzten Sportlers niedriger** (z. B. mutmaßliche Einwilligung im Interesse des Sportlers bei Bewusstlosigkeit) als bei einem aufschiebbaren Wahleingriff. Nach der Rechtsprechung des BGH ist eine Aufklärung am Tag vor dem Eingriff nur rechtzeitig, wenn es sich um „einfache“ Eingriffe und „solche mit geringen bzw. wenig einschneidenden Risiken“ handelt (siehe auch BGH VersR 1992, 961).

Der BGH (BGH NJW 1992, 2351) regelt die **zeitliche Abfolge für ein Aufklärungsgespräch** wie folgt:

„Ein Arzt, der einem Patienten eine Entscheidung über die Duldung eines operativen Eingriffs abverlangt und für diesen Eingriff bereits einen Termin bestimmt, hat dem Patienten vorher auch bereits die Risiken aufzuzeigen, die mit diesem Eingriff verbunden sind.“

Es wird sich daher in der Praxis zeigen, ob die pauschale Vorgabe des Gesetzgebers zur ausreichenden Zeit am Vortag des operativen Eingriffs von Seiten der Rechtsprechung auch auf elektive Eingriffe Anwendung findet.

Von Aufklärungsbögen, die der Patient unterschreibt, hat er eine Abschrift zu erhalten (§ 630e Abs. 2 S. 2 BGB).

Die Einwilligung des aufgeklärten Patienten lässt die Rechtswidrigkeit des ärztlichen Heileingriffs entfallen. Die Einwilligung bedeutet für den Patienten einen **Rechtsgutverzicht**, der nach außen manifestiert werden und üblicherweise vor dem ärztlichen Eingriff erfolgen muss. Neben der Einwilligungsfähigkeit als natürliche Einsichts- und Urteilsfähigkeit (Cave: Minderjährige, § 630e Abs. 5 BGB beachten: Erläuterungen des Eingriffs u. a. anhand des Entwicklungsstands des Kindes) ist **Freiwilligkeit und Dispositionsbefugnis** erforderlich (Cave: kein genereller Verzicht auf Leben wegen der in § 216 StGB normierten Tötung auf Verlangen). Der Eingriff darf zudem **nicht gegen die guten Sitten verstoßen** (siehe § 228 StGB, z. B. Verstümmelungsoperationen).

§ 228 StGB: Einwilligung

Wer eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt, handelt nur dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt.

Der Arzt muss den Eingriff subjektiv in Kenntnis der Einwilligung vornehmen.

Nach allgemeiner Auffassung führt ein Verstoß gegen die Selbstbestimmungsaufklärung dazu, dass der Eingriff mangels Einwilligung rechtswidrig (vgl. z. B. BGH NSTZ 2004, 442) ist.

Der BGH (MedR 1996, 213, 214) führt dazu aus:

„Die Grundaufklärung setzt nämlich voraus, dass der Patient auch einen Hinweis auf das schwerste in Betracht kommende Risiko erhalten hat, welches dem Eingriff spezifisch anhaftet.“

Gerade bei möglicherweise **verheerenden Ausgängen** fordert der BGH sogar bei einem Risiko von 1:2–3 Mio., dass der Patient rechtzeitig und umfassend aufzuklären ist und aufgeklärt wird (BGH NJW 1992, 743). Dabei ist zu beachten, dass sogar eine erhöhte **Aufklärungspflicht** über unerwünschte Wirkungen und Kontraindikationen sowie eine erhöhte **Dokumentationspflicht** bei Therapieversuchen außerhalb zugelassener Anwendungsgebiete bestehen (Dettmeyer 2006, Ulsenheimer 2015).

BGH (MedR 2001, 421)

„Verwirklicht sich aber ein zweites aufklärungspflichtiges Risiko, über das der Patient nicht aufgeklärt worden ist, haftet der Arzt auch für beide Risiken, also auch für das Risiko, über das er aufgeklärt hat. Der Mangel der Grundaufklärung kann sich zu Lasten des Arztes auswirken, wenn nämlich dem Patienten nicht einmal ein Hinweis auf das schwerstmögliche Risiko gegeben worden ist, sodass er sich keine Vorstellung machen konnte.“

Bei neuen Methoden mit ungeklärten Risiken muss eine besonders umfassende und eindringliche Aufklärung des Patienten erfolgen (BGH Ur. v. 13.6.2006 – VI ZR 323/04; Ulsenheimer 2015). Je weniger ein Eingriff medizinisch indiziert ist, desto umfassender hat die Aufklärung zu erfolgen (BGH Ur. v. 14.3.2006 – VI ZR 279/04). Die Aufklärungspflicht hat sich auch auf die Anwendung **nicht zugelassener Arzneimittel** zu erstrecken (BGH NSTZ 1996, 34).

Die **Beweislast** für eine ordnungsgemäße, vollständige, zeitige und richtige Selbstbestimmungsaufklärung trägt der Arzt (BGH MedR 1990, 329–331; § 630h Abs. 2 S. 1 BGB) – und für einen Verstoß gegen die Grundsätze der Informationspflichten nach § 630c BGB der Patient. Grundsätzlich muss eine Aufklärung nach den allgemeinen Regeln mündlich erfolgen (§ 630e Abs. 2 S. 1 Nr. 1 BGB); es besteht **keine Formerfordernis der Schriftlichkeit**. Aus beweisrechtlichen Gründen empfiehlt sich aber eine schriftliche Dokumentation, ggf. die Durchführung in der Anwesenheit von **Zeugen**.

Grundlegend führt der BGH aus (VersR 1994, 1235):

„Der Sache nach verbleibt es bei den allgemeinen Regeln der Darlegungs- und Beweislast des Arztes dafür, dass er den Patienten nicht nur vollständig, sondern auch rechtzeitig aufgeklärt hat. Entsprechenden Vortrag des Patienten hat der Arzt zu widerlegen.“

Das **alleinige Aushändigen eines Aufklärungsbogens** an den Patienten zur Unterschrift entspricht **nicht** den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Aufklärung (BGH NJW 1994, 793, nun in § 630e Abs. 2 S. 1 BGB). Der Arzt kann sich unter Umständen damit exkulpieren, dass der Patient auch in Kenntnis aller Umstände in den Eingriff eingewilligt hätte (hypothetische Einwilligung, siehe auch § 630h Abs.

2 S. 2 BGB). Jedoch ist dieser Nachweis gerade bei einem nicht vital indizierten diagnostischen Eingriff streng zu bewerten (OLG Koblenz, VersR 2003, 1313 f., vgl. auch BGH NJW 2007, 2.767 ff.).

In einer neueren Entscheidung (allerdings noch nicht auf Basis des PatRG) führt der BGH (BGH, VersR 2014, 588 ff.) aus:

„An den dem Arzt obliegenden Beweis dürfen allerdings keine unbilligen und übertriebenen Anforderungen gestellt werden. Danach hat der Tattrichter die besondere Situation, in der sich der Arzt während der Behandlung des Patienten befindet, ebenso zu berücksichtigen wie die Gefahr, die sich aus dem Missbrauch seiner Beweislast durch den Patienten zu haftungsrechtlichen Zwecken ergeben kann. Ist einiger Beweis für ein gewissenhaftes Aufklärungsgespräch erbracht, sollte dem Arzt im Zweifel geglaubt werden, dass die Aufklärung auch im Einzelfall in der gebotenen Weise geschehen ist; dies auch mit Rücksicht darauf, dass aus vielerlei verständlichen Gründen Patienten sich im Nachhinein an den genauen Inhalt solcher Gespräche, die für sie etwa vor allem von therapeutischer Bedeutung waren, nicht mehr erinnern ... Schriftliche Aufzeichnungen im Krankenblatt über die Durchführung des Aufklärungsgesprächs und seinen wesentlichen Inhalt sind nützlich und dringend zu empfehlen. Ihr Fehlen darf aber nicht dazu führen, dass der Arzt regelmäßig beweisfällig für die behauptete Aufklärung bleibt. Allein entscheidend ist das vertrauensvolle Gespräch zwischen Arzt und Patient. Deshalb muss auch der Arzt, der keine Formulare benutzt und für den konkreten Einzelfall keine Zeugen zur Verfügung hat, eine faire und reale Chance haben, den ihm obliegenden Beweis für die Durchführung und den Inhalt des Aufklärungsgesprächs zu führen.“

Aus der Musterberufsordnung (in der Fassung des 118. Deutschen Ärztetages 2015 in Frankfurt): § 8 Aufklärungspflicht MBO; bitte rechtlich verbindliche Vorgaben in den Berufsordnungen der Landesärztekammern beachten

Zur Behandlung bedürfen Ärztinnen und Ärzte der Einwilligung der Patientin oder des Patienten. Der Einwilligung hat grundsätzlich die erforderliche Aufklärung im persönlichen Gespräch vorauszugehen. Die Aufklärung hat der Patientin oder dem Patienten insbesondere vor operativen Eingriffen Wesen, Bedeutung und Tragweite der Be-

handlung einschließlich Behandlungsalternativen und die mit ihnen verbundenen Risiken in verständlicher und angemessener Weise zu verdeutlichen. Insbesondere vor diagnostischen oder operativen Eingriffen ist soweit möglich eine ausreichende Bedenkzeit vor der weiteren Behandlung zu gewährleisten. Je weniger eine Maßnahme medizinisch geboten oder je größer ihre Tragweite ist, umso ausführlicher und eindrücklicher sind Patientinnen oder Patienten über erreichbare Ergebnisse und Risiken aufzuklären.

90.3 Informationspflichten

Markus Parzeller

Von der Selbstbestimmungsaufklärung zu unterscheiden sind die Informationspflichten nach § 630c BGB, die früher auch als Sicherungsaufklärung oder therapeutische Aufklärung bezeichnet wurde. Diese **Informationspflichten** (vgl. BGH, Urt. vom 16.11.2004 – VI ZR 328/03) dienen der Beratung, Information und Aufklärung im Interesse des Patienten und greift weiter als die Selbstbestimmungsaufklärung, z. B. Aufklärung über Medikamentenunverträglichkeiten, Nebenwirkungen, Fahrtauglichkeit, Sportausübung nach operativem Eingriff etc.

Nach dem Willen des Gesetzgebers (BR-Drs. 312/12 S. 29; BT-Drs. 17/10488 S. 21, ausführlich siehe Parzeller und Zedler 2013a) umfasst § 630c BGB u. a. Informationen des Patienten über:

- Diagnose
- Entwicklung
- Therapie
- Erforderliche Maßnahmen
- Erörterung der Anamnese
- Notwendigkeit von Befunderhebungen
- Medikation: Unverträglichkeiten, Nebenfolgen etc.

Rechtlich erheblich umstritten ist die Offenbarungspflicht über eigene und fremde Fehler bei der medizinischen Behandlung auf Nachfrage des Patienten oder zur Abwendung von gesundheitlichen Gefahren nach § 630c Abs. 2 S. 2 und 3 BGB (ausführlich siehe Parzeller und Zedler 2013a, Parzeller et al. 2014). Hier empfiehlt sich im Zweifelsfall eine fachliche Beratung durch einen Juristen, aufgrund der erheblichen Konsequenzen, die eine solche Fehleroffenbarung mit sich bringen kann.

90.4 Behandlungsfehler

Markus Parzeller

Ein möglicher ärztlicher Behandlungsfehler kann sich in vielfältiger Weise ereignen. Im Ergebnis kann er für den Patienten folgenlos bleiben oder aber zu einem vorübergehenden oder bleibenden Schaden bis hin zum Tod des Patienten führen (Parzeller 2002b; StA Fulda Az. 1 Js 1270/03: Tod eines Tanzsportlers nach dem Einsatz so nicht zugelassener Medikation und fehlender Überwachung in der Nephrologie: kritische Bewertung bei Parzeller und Bratzke 2007).

90.4.1 Wrong-Site Surgery

Bei einer Vielzahl möglicher Fehler während ärztlichen Behandlungen handelt es sich bei Verwechslungen von zu operierenden Körperseiten bzw. -stellen oder gar der Patienten um typische vermeidbare Behandlungsfehler (z. B. Amputation des falschen Beins). In einem 10-Jahres-Zeitraum wurden nach Angaben einer amerikanischen Versicherungsstudie 331 Klagen auf Behandlungsfehler durch „Wrong-Site Surgery“ gestützt. In 225 Fällen waren Orthopäden involviert.

Besonders verwechslungssträchtig war die **Knieregion**, z. B. bei der Kniearthroskopie (Canale 2005, Cowell 1998). Schätzungen gehen von einer Wahrscheinlichkeit von ca. 20–25 % aus, dass einem Orthopäden während seiner Laufbahn eine Seitenverwechslung bei einer ärztlichen Behandlung unterläuft (Meinberg und Stern 2003, Canale 2005). Etwa 2 % der Klagen gegen Orthopäden in den USA beziehen sich auf Behandlungsfehler durch Wrong-Site Surgery (DiGiovanni et al. 2005).

90.4.2 Unterlassene ärztliche Maßnahmen

Der behandelnde Arzt kann als Garant für seinen Patienten auch für unterbliebene ärztliche Maßnahmen straf- und/oder zivilrechtlich haften. Bereits eine **fehlende Aufnahmeuntersuchung** kann ein grobes Fehlverhalten darstellen. Die **Anamnese** gehört

zu den elementaren und unverzichtbaren Grundregeln der Medizin (OLG Düsseldorf VersR 1998, 1155).

Ein **Diagnose-Irrtum** ist haftungsrechtlich beachtlich, wenn er eine völlig unvertretbare Fehlleistung darstellt, auf dem Unterlassen elementarer Befunderhebungen beruht oder eine Arbeitsdiagnose im weiteren Behandlungsverlauf nicht überprüft wird (OLG Frankfurt VersR 1997, 1358).

Das **Unterlassen der erforderlichen Diagnostik** bei deutlichen Anzeichen einer schweren Erkrankung, z. B. Übersehen einer Hirnblutung unter gerinnungshemmender Medikation und Erbrechen unklarer Genese, weist auf einen groben Behandlungsfehler hin, der zivilrechtlich eine **Beweislastumkehr** zur Folge haben kann (OLG Celle, VersR 1994, 1237 f.; OLG Stuttgart, MedR 1997, 275 ff.; Parzeller 2002b). Gerade **fundamentale Diagnosefehler** können eine Umkehrung der Beweislast rechtfertigen, wenn sich dem Arzt der Verdacht einer schweren Erkrankung hätte aufdrängen müssen. Nach § 630h Abs. 5 S. 2 BGB kann ein einfacher (!) Befunderhebungs- oder Befundsicherungsfehler, wenn bei einer unterstellten Diagnose erforderliche Befunde nicht erhoben bzw. gesichert werden, als grober Behandlungsfehler mit der Folge der Beweislastumkehr zu Lasten des Arztes gewertet werden. Dies setzt voraus, dass der „Befund mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis gebracht hätte, das Anlass zu weiteren Maßnahmen gegeben hätte, und wenn das Unterlassen solcher Maßnahmen grob fehlerhaft gewesen wäre“ (BR-Drs. 312/12 S. 44 f.; BT-Drs. 17/10488 S. 31). Es darf sich dabei nicht um einen einfachen reinen Diagnosefehler handeln.

„Grundsätzlich kann das Nichterkennen einer erkennbaren Erkrankung und der für sie kennzeichnenden Symptome als Behandlungsfehler gewertet werden“ (BGH MedR 2004, 107 f.).

So wird das **Unterlassen notwendiger CT-Befunden** von der Rechtsprechung regelmäßig als grober Behandlungsfehler gewertet (BGH NJW 1998, 1782, 1783). Ein ärztliches Fehlverhalten liegt auch vor, wenn der Arzt **objektiv unrichtige Diagnosen** stellt, weil er die notwendige Befunderhebung (z. B. körperliche Untersuchung, CT, neurologisch-neurochirurgisches Konsil, Labor etc.) entweder vor der Di-

agnosestellung oder zur erforderlichen Überprüfung der Diagnose unterlässt (BGH MedR 2004, 107, 108).

Das **Unterlassen von Anordnungen**, z. B. bei einem eilbedürftigen drohenden Gefäßverschluss im Bein, kann einen groben Behandlungsfehler darstellen (OLG Celle, Urt. v. 25.6.1984–1 U 44/83: Konsequenz für den Patienten: Oberschenkelamputation, Nierenschaden).

Das OLG Hamm (VersR 1988, 601) erläutert in seinen Leitsätzen:

„Ist das Ergebnis der Abwägung und Gewichtung der dem Arzt vorliegenden Erkenntnisse vorwerfbar von grundlegendem Irrtum geprägt und geht der Arzt nicht mit dem gebotenen Nachdruck daran, seine Zweifel rasch zu klären, ist ihm ein grober Behandlungsfehler vorzuwerfen. Fehldiagnosen (...), die häufiger vorkommen können, müssen durch Ausschöpfen aller Erkenntnismöglichkeiten ausgeschlossen werden, weil dem Patienten schwerer gesundheitlicher Schaden droht. Unterlässt der Chirurg trotz eindeutiger Symptome die gebotene Appendektomie, so ist das Unterlassen auch einer Sonografie ein grober Behandlungsfehler.“

90.4.3 Fehlerhafte Medikation

Bei der Medikation des verletzten Sportlers sind neben der gewissenhaften **Indikationsstellung** auch die Anwendbarkeit im Hinblick auf **Dopinglisten** (**Anhänge zum AMG bzw. geplanten Anti-Doping-Gesetz, WADA-Verbotsliste etc.**), **Ausnahmegeheimigungen** und etwaige schriftliche Meldungen zu beachten. Der Arzt hat die in der Verabreichung des Medikaments liegenden Gefahren mit dem Patienten zu besprechen (BGH Urt. v. 15.3.2005 – VI ZR 289/03; OLG München, VersR 1989, 198). Diesbezüglich wird erwartet, dass er die **Kontraindikationen des Arzneimittels**, auf die in der Gebrauchsinformationen hingewiesen wird, kennt (OLG Stuttgart, AHRS 26. Lfg. I 91, 43).

Eine kontraindizierte Behandlung (anwendbar auch auf die Verabreichung von Dopingsubstanzen ohne medizinische Indikation) darf auch nicht auf nachhaltigen Wunsch des Patienten vorgenommen werden (OLG Karlsruhe, MedR 2003, 104 ff.).

Nach dem OLG Zweibrücken (MedR 1983, 194) stellt es einen Behandlungsfehler dar, wenn eine medikamentöse Therapie nicht beendet wird, obwohl erkennbare, vom Hersteller beschriebene für die Gesundheit des Patienten nicht mehr tolerable **Nebenwirkungen** auftreten.

Allerdings ist auch die **ärztliche Therapiefreiheit** zu beachten. So besteht keine Beschränkung der ärztlichen Therapiefreiheit durch das Arzneimittelgesetz (AMG) beim Einsatz nicht zugelassener Medikation (Einsatz von Aciclovir bei Enzephalitis, OLG Köln VersR 1991, 186–189; Cave: Aufklärung).

Neue Therapiekonzepte können angezeigt sein, wenn sie

- risikoärmer sind,
- bessere Heilungschancen versprechen und
- in der medizinischen Wissenschaft im Wesentlichen unumstritten sind (OLG Köln 1992 VersR 754; Cave: Aufklärung).

Medikamente können zur Abwendung lebensbedrohlicher Komplikationen **höher und riskanter dosiert** werden (OLG Koblenz MedR 2000, 37–40; Cave: Sicherungsaufklärung bzw. Informationspflichten nach § 630c BGB). Jedoch sind **bei fort-dauernden Schmerzen** nicht nur die Symptome, sondern auch die **Ursachen** zu erforschen und zu behandeln (OLG Hamm, VersR 1989, 293–294).

Das OLG Nürnberg (OLG Nürnberg VersR 88, 1.050) hat einer Klage stattgegeben, weil die Verabreichung von Schmerz- und Behandlungsmitteln bei abdominalen Schmerzen ohne Ursachenabklärung damals einen erheblichen Behandlungsfehler dargestellt hat.

„Bei infausten Prognosen wird eine medizinisch gebotene schmerzlindernde Medikation beim sterbenden Patienten nicht unzulässig, wenn als Nebenfolge der Tod beschleunigt wird“ (indirekte Sterbehilfe, BGH NJW 1997, 807 ff.; ausführlich siehe Laux et al. 2012, 2013a, 2013b).

Das OLG Koblenz (AHRS 46. Lfg. VI/94 Nr. 2310 Seite 17) bezog 1990 eindeutig zur ärztlichen **Medikamentenüberwachung** Stellung:

„Die ärztlich gebotene Medikationsüberwachung muss bereits auf die ersten Anzeichen schädlicher Folgen achten und die ärztlichen Schutzmaßnahmen

müssen zum frühest möglichen Zeitpunkt einsetzen, um gravierende Schadensfolgen erst gar nicht entstehen zu lassen.“

Die ordnungsgemäße Überwachung einer medikamentösen Therapie wird immer wieder von der Rechtsprechung betont. Das OLG Bamberg (AHRS 5. Lfg. XI/87 Nr. 2705 S. 3) führte bereits 1975 aus:

„Wenn von einer medikamentösen Behandlung schädliche Folgen zu erwarten sind, ist der Arzt verpflichtet, alles ihm Zumutbare zu tun, um die Nebenwirkungen in ihrem Anfangsstadium zu erkennen und zu vermeiden.“

90.4.4 Fehlende Überwachung

Der BGH (BGH VersR 1984, 356, 358) stellte klar, dass Ärzte von der **Verlegung auf eine Wachstation** Gebrauch machen müssen, wenn die erforderliche ständige Überwachung auf der Normalstation nicht gesichert ist, da nur bei jederzeitigem Sichtkontakt schwere Schädigungen ggf. vermeidbar sind. Nach dem OLG Köln (VersR 1996, 1278) sind an **Schutzpflichten** des Arztes für den Patienten **strenge Anforderungen** zu stellen, wenn sie sich einerseits mit geringem Aufwand erfüllen lassen und andererseits dem Patienten erhebliche Gefahren drohen, wenn sich das Risiko verwirklicht.

90.4.5 Erhebliche Organisationsmängel und -defizite sowie fehlender Arzt- bzw. Facharztstandard

Nach der Rechtsprechung liegt ein Behandlungsfehler vor, wenn nach ihrem Ausbildungs- und Erfahrungsstand **nicht befähigten Personen** bestimmte Eingriffe in die körperliche Integrität des Patienten dennoch übertragen werden (BGH NJW 1978, 1681; OLG Köln MedR 1987, 192, siehe nunmehr auch zur Vermutungswirkung nach § 630h Abs. 4 BGB bei mangelnder Befähigung des Behandelnden). Patienten haben zudem **Anspruch auf die Einhaltung des Facharztstandards** sowie die Überwachung und Anleitung von Berufsanfängern (BGH NJW 1988, 2298–2300). Bei Beteiligung mehrerer Ärzte gehört

die **gegenseitige Informationspflicht** zu den Schutzpflichten gegenüber dem Patienten (BGH NJW 1999, 1779 f.). Wer als Arzt besondere **Gefahrenquellen** schafft oder verstärkt, hat die notwendigen Vorkehrungen zum Schutz des Patienten zu treffen (BGH NJW 2003, 2309 f.).

Die alleinige Behandlung durch nicht überwachte Ärzte ohne abgeschlossene Facharztausbildung bzw. mit fehlender Kenntnis und Erfahrung eines Facharztes begründet den Vorwurf des Organisationsverschuldens (BGH MedR 1993, 447 ff. mit Urteilsbesprechung).

Entsprechend der BGH-Rechtsprechung (Entscheidung vom 10. 3. 1992 – VI ZR 64/91) besteht ein Indiz dafür, dass die unzureichende Qualifikation der Ärzte ursächlich für den Behandlungsfehler sein kann. Nach der Rechtsprechung des OLG Düsseldorf (Urt. v. 2.10.1985–8 U 100/83) trifft den **Krankenhausträger dann die Beweislastumkehr**, wenn ein tödlicher Schaden bei richtiger und rechtzeitiger Behandlung vermieden worden wäre. Bei organisatorischen Mängeln (siehe auch Neelmeier 2014) ist die Rechtsprechung des OLG Hamm (VersR 1994, 729) und des OLG Köln (VersR 1992, 452) bemerkenswert.

OLG Hamm: *„Eine Beweislastumkehr bei dem Kausalitätsbeweis kommt auch bei groben Organisationsmängeln in einer Klinik zu Lasten des Klinikträgers in Betracht, wenn durch den Organisationsmangel das Spektrum der für die Schädigung des Klägers in Frage kommenden Ursachen besonders verbreitert bzw. verschoben worden ist.“*

OLG Köln: *„Minderungen des organisatorischen Qualitätsstandards, die geeignet sind, den Behandlungserfolg zu gefährden (hier: Fehlen ärztlicher Assistenz), können die Beweislast zum Nachteil der Behandlungsseite verlagern. Ist für einen Eingriff die Mitwirkung einer erfahrenen ärztlichen Assistenz erforderlich, kann diese Aufgabe nicht von einer Studierenden im praktischen Jahr wahrgenommen werden.“*

90.4.6 Doping

Die Anwendung von Arzneimitteln, die nicht dem Zweck der Behandlung einer Erkrankung, sondern

nur der **Leistungssteigerung von Sportlern** (Doping) dienen, ist nach dem AMG verboten. Seit 1.11.2007 ist das Gesetz zur Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport in Kraft getreten, das zu Änderungen des BKA-G (Bundeskriminalamtgesetzes) und des AMG (Arzneimittelgesetzes) geführt hat (Hofmann 2008, Parzeller et al. 2008, Parzeller und Rüdiger 2007a, 2007b, Parzeller und Centamore 2008, Raschka et al. 2008, Parzeller 2014). Relevante Änderungen sind die Einführung einer Besitzstrafbarkeit für Dopingsubstanzen (Besitz einer nicht geringen Menge; vgl. auch Dopingmittelmengenverordnung [DmMV]), Modifikationen der nebenstrafrechtlichen Bestimmungen des § 95 AMG und die Rückausnahme von den Ausnahmen des AMG, um nach dem Willen des Gesetzgebers z. B. Blutdoping besser erfassen zu können. Zwischenzeitlich wurden seit 2007 immer wieder Änderungen am AMG vorgenommen, insbesondere wurde die intransparente Verweisungstechnik geändert (weitergehend siehe Parzeller und Prittwitz 2009a, 2009b, Parzeller 2010, Parzeller 2011a). Das Gesetz wurde inzwischen evaluiert (Bundesregierung 2012). Die Ergebnisse staatlicher Dopingbekämpfung im Spitzen- und Hochleistungssport sind aber durchaus ernüchternd (Parzeller et al. 2013a, 2013b, Parzeller 2014). Im November 2014 wurde ein Referentenentwurf für ein eigenständiges Anti-Doping-Gesetz (AntiDopG-E) und im März 2015 der Gesetzentwurf der Bundesregierung (BR-Drs. 126/15) vorgelegt, der möglicherweise ab Januar 2016 dazu führen könnte, dass die bisherigen staatlichen Dopingnormen im AMG nur noch auf Altfälle Anwendung finden und nach Inkrafttreten des AntiDopG für zukünftige Dopingtatbestände Makulatur sind. Es empfiehlt sich daher, als Sportarzt regelmäßig die (rechtlichen) Änderungen, z. B. auch bei den WADA-Verbotslisten (> Kap. 4), aufmerksam zu verfolgen. Nach dem neuen Entwurf sind neben den bereits im AMG vorgesehenen Tatbeständen weitergehende Verbots- und Straftatbestände beim Fremddoping (z. B. Herstellen, Handel treiben, Veräußern und Abgabe von Dopingmitteln) sowie ein Verbot und eine Strafbarkeit des Selbstdopings, wenn das Doping in einem Wettbewerb des organisierten Sports erfolgt, vorgesehen (siehe Gesetzentwurf der Bundesregierung vom 27.3.2015 – BR-Drs. 126/15).

Auszüge aus dem AMG, Stand Mai 2015

§ 6a AMG (Arzneimittelgesetz)

- (1) Es ist verboten, Arzneimittel nach Absatz 2 Satz 1 zu Dopingzwecken im Sport in den Verkehr zu bringen, zu verschreiben oder bei anderen anzuwenden, sofern ein Doping bei Menschen erfolgt oder erfolgen soll.
- (2) Absatz 1 findet nur Anwendung auf Arzneimittel, die Stoffe der in der jeweils geltenden Fassung des Anhangs des Übereinkommens gegen Doping (Gesetz vom 2. März 1994 zu dem Übereinkommen vom 16. November 1989 gegen Doping, BGBl. 1994 II S. 334) aufgeführten Gruppen von verbotenen Wirkstoffen oder Stoffe enthalten, die zur Verwendung bei den dort aufgeführten verbotenen Methoden bestimmt sind. (...)
- 2a. Es ist verboten, Arzneimittel oder Wirkstoffe, die im Anhang zu diesem Gesetz genannte Stoffe sind oder enthalten, in nicht geringer Menge zu Dopingzwecken im Sport zu erwerben oder zu besitzen, sofern das Doping bei Menschen erfolgen soll. (...)

§ 95 AMG (Strafvorschriften)

- (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer (...)
 - 2a. entgegen § 6a Abs. 1 Arzneimittel zu Dopingzwecken im Sport in den Verkehr bringt, verschreibt oder bei anderen anwendet,
 - 2b. entgegen § 6a Abs. 2a Satz 1 ein Arzneimittel oder einen Wirkstoff erwirbt oder besitzt, (...)
- (2) Der Versuch ist strafbar.
- (3) In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter
 1. durch eine der in Absatz 1 bezeichneten Handlungen
 - a) die Gesundheit einer großen Zahl von Menschen gefährdet,
 - b) einen anderen der Gefahr des Todes oder einer schweren Schädigung an Körper oder Gesundheit aussetzt oder
 - c) aus grobem Eigennutz für sich oder einen anderen Vermögensvorteile großen Ausmaßes erlangt oder
 2. in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2a
 - a) Arzneimittel zu Dopingzwecken im Sport an Personen unter 18 Jahren abgibt oder bei diesen Personen anwendet oder
 - b) gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat. (...)
- (4) Handelt der Täter in den Fällen des Absatzes 1 fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

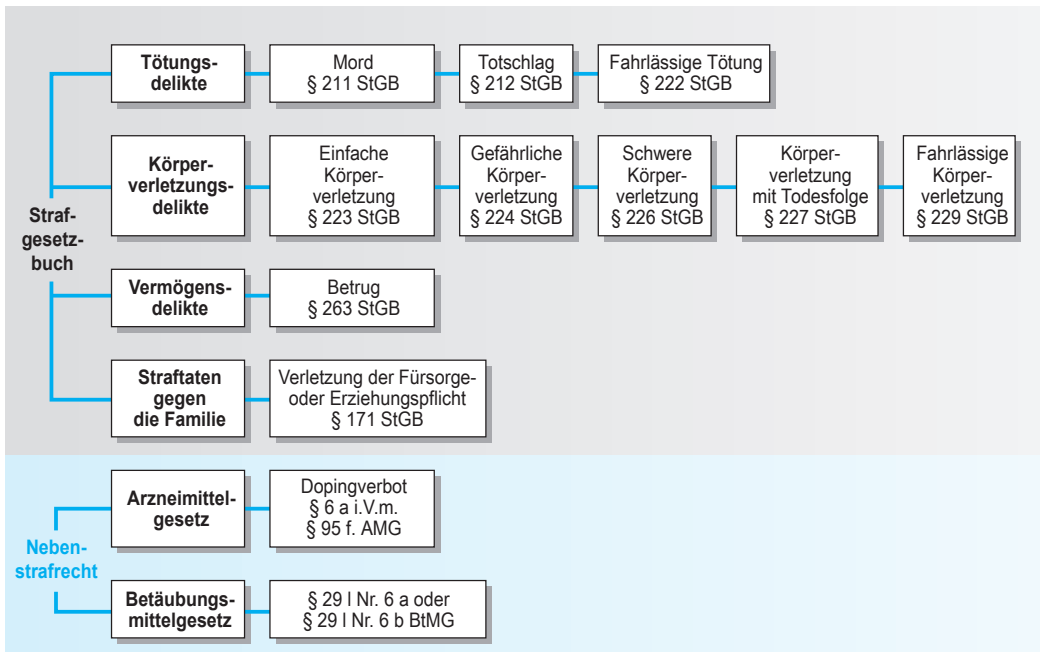


Abb. 90.1 Doping und mögliche einschlägige Delikte. [L106]

Ärztliche Dopingmaßnahmen können für den Arzt schwere rechtliche Folgen im Bereich des Zivilrechts (Striegel und Vollkommer 2001), des Strafrechts (Dinkel et al. 2014, Fischer 2015, Leipold 2006, Parzeller 2001, Parzeller und Rüdiger 2007b, Parzeller et al. 2008, 2009, Parzeller 2011a, 2011b; ➤ Abb. 90.1) oder des Berufsrechts (Bezirksberufsgericht für Ärzte Stuttgart, Urt. v. 3.3.1999 – BBG 16/98. MedR 2000, 105–106: Verschreibung von Anabolika durch eine Ärztin an einen Bodybuilder ohne medizinische Indikation; VGH BW, Urt. v. 5.2.2004 – DL 17 S 11/03. ESVGH 54, 166–168: Disziplinarmaßnahmen bei einem Polizeibeamten wegen Handels mit anabolen Steroiden; OVG Rhein.-Pfalz, Urt. v. 20.9.2005 – A 10556/05. MedR 2006, 301–305: zum Widerruf der Approbation eines Arztes u. a. wegen Verschreibens von Arzneimitteln zu Dopingzwecken) haben. Verurteilungen durch das LG Berlin (z. B. Arzt: Urt. v. 12.1.2000 – 28 Js 195/97; Apotheker: Urt. v. 22.1.2009 – [511] 68 Js 533/06 KLS [15/08]) und Revisionsverfahren vor dem BGH (BGH NJW 2000, 1.506 ff.; BGH, StoffR 2010, 103–104 = NStZ 2010, 170–171) zeigen auf, dass es sich bei Doping durch Ärzte um **keine Kavaliersdelikte** handelt.

90.4.7 Kausalitätsfragen zu ärztlichen Behandlungsfehlern

In § 630h BGB hat der Gesetzgeber nunmehr einige Fallkonstellationen bezüglich der Beweislast bei der Haftung für Behandlungs- und Aufklärungsfehler (ausführlich siehe Parzeller und Zedler 2014) geregelt:

- § 630h Abs. 1 BGB: voll beherrschbares Risiko
- § 630h Abs. 2 BGB: Einwilligung und Aufklärung
- § 630h Abs. 3 BGB: Dokumentationsmängel
- § 630h Abs. 4 BGB: mangelnde Befähigung
- § 630h Abs. 5 BGB: grober ärztlicher Behandlungsfehler

Zwar trägt der Patient oder der Angehörige eines verstorbenen Patienten in einem zivilen Rechtsstreit zunächst die Darlegungs- und Beweislast für eine Pflichtverletzung des Arztes. In den neuen Regelungen des § 630h BGB gibt es aber zugunsten des Patienten Beweiserleichterungen (Vermutungswirkung) bis hin zur Beweislastumkehr. Beim Vorliegen eines **groben Behandlungsfehlers** kann sich z. B. die **Beweislast zu Lasten des Arztes** umkehren (§ 630h Abs. 5 BGB), der dann dezidiert darlegen muss, dass

es auch bei ordnungsgemäßer Behandlung des Patienten zum Schadenseintritt gekommen wäre. Ein Behandlungsfehler ist immer dann als grob zu bewerten, wenn ein medizinisches Fehlverhalten vorliegt, das **aus objektiver Sicht nicht mehr verständlich** erscheint, wenn ein solcher Fehler dem Arzt „schlechterdings nicht unterlaufen darf“ (BGH VersR 2002, 1026; MDR 2001, 1113, 1114).

Auch ein **Diagnose-Irrtum** kann als grober Behandlungsfehler zu werten sein und einen schweren Verstoß gegen die Regeln der ärztlichen Kunst darstellen, insbesondere wenn durch eine **ungezielte Medikation das Krankheitsbild verschleiert** wird (BGH NJW 1988, 1513). So wertete das OLG Hamm (VersR 1989, 292) das Verhalten eines Arztes als grob fehlerhaft, weil er bei deutlicher Symptomatik eine Erkrankung verkannt und keine gezielte Diagnostik vorgenommen hatte. Das soll sogar gelten, wenn noch weitere Behandlungsfehler durch andere Ärzte hinzukommen (OLG Frankfurt, VersR 2000, 853).

Der BGH (BGH MedR 1991, 83) bewertet das Unterlassen von üblichen und notwendigen Untersuchungsmaßnahmen als groben Behandlungsfehler.

In einer neueren Entscheidung führt der BGH aus (VersR 2004, 790 f., siehe auch § 630h Abs. 5 S. 2 BGB):

„Eine fehlerhafte Unterlassung der medizinisch gebotenen Befunderhebung führt zu einer Umkehr der Beweislast hinsichtlich der Kausalität des Behandlungsfehlers für den eingetretenen Schaden, wenn sich bei der gebotenen Befunderhebung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein reaktionspflichtiges positives Ergebnis gezeigt hätte und wenn sich die Verkennung dieses Befundes als fundamental oder die Nichtreaktion hierauf als grob fehlerhaft darstellen würde.“

90.5 Dokumentation und Einsichtnahme in die Krankenakte

Markus Parzeller

Der BGH sieht in der Dokumentation eine selbstverständliche **therapeutische Pflicht** (BGH NJW

1978, 2337, 2339; BGH VersR 1986, 983; BGH NJW 1987, 1482, 1483). Die ärztliche Dokumentation dient nicht nur dem Interesse des Arztes als Gedächtnisstütze, sondern primär als Ausfluss seiner therapeutischen Pflicht, sekundär aber auch als **Rechenschaftspflicht gegenüber dem Patienten** (BGH, NJW 1978, 2337, 2339; OLG Köln NJW 1982, 704). Die ärztliche Dokumentation soll zudem die ordnungsgemäße Weiter- oder Mitbehandlung durch einen anderen Arzt ermöglichen (BGH NJW 1983, 328).

Eine **unterlassene Dokumentation** kann im Arzthaftungsprozess keine eigene Anspruchsgrundlage sein. Sie führt aber dazu, dass dem klagenden Patienten der Beweis bereits dargelegter Behandlungsfehler noch zusätzlich erleichtert wird. Für **besonders gefahrenträchtige**, aber beherrschbare Handlungsweisen auf Arztseite ist anerkannt, dass eine **ausführliche Dokumentation** vorzunehmen ist. Handelt etwa ein **Berufsanfänger** selbstständig, hat er alle wesentlichen Punkte genau zu dokumentieren, um wenigstens eine gewisse Kontrolle im Interesse seiner Ausbildung und vor allem auch im Interesse des Patienten zu gewährleisten.

In der Konsequenz kann die unzureichende Dokumentation als Verletzung einer **vertraglichen Nebenpflicht** dazu führen, dass das Gericht davon ausgeht, dass eine Aufklärung, Beratung oder ärztliche Maßnahme nicht erfolgt ist, insbesondere wenn die Sicherung der Aufklärungsmaßnahme für den Arzt als Vorichtsmaßnahme sehr nahe liegt (OLG Zweibrücken, NJW-RR 2000, 235, 236; BGH NJW 1999, 3.408 ff.).

Dieser Rechtsprechung trägt der Gesetzgeber durch § 630f und § 630h Abs. 3 BGB (Beweislast bei unzureichender Dokumentation) Rechnung. Aus § 630f Abs. 1 BGB besteht für den Behandelnden die vertragliche Nebenpflicht zur Dokumentation. Als Gründe werden Aspekte der Behandlung, der Weiterbehandlung und der Schutz vor Informationsverlust, aber auch wirtschaftliche Gründe (Vermeidung von Doppeluntersuchungen) und nunmehr auch die Beweissicherung genannt (BR-Drs. 312/12 S. 37; BT-Drs. 17/10488 S. 25 f.). Die Dokumentation hat in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang auf Papier oder elektronisch zu erfolgen. Berichtigungen und Änderungen sind nur zulässig, wenn unter Angabe des Datums die Erkennbarkeit des ursprünglichen Inhalts gewährleistet bleibt (Anforderungen gelten

auch für elektronisch geführte Patientenakten, z. B. Umsetzung durch Historienfunktion).

Die Dokumentation muss sämtliche aus fachlicher Sicht wesentlichen Maßnahmen und Ergebnisse für die derzeitige und zukünftige Behandlung umfassen, z. B.:

- Anamnese
- Diagnosen
- Untersuchungen
- Untersuchungsergebnisse
- Befunde
- Therapien und deren Wirkungen
- Eingriffe und deren Wirkungen
- Einwilligungen und Aufklärungen

Nach § 630 g BGB hat der Patient bis auf wenige Ausnahmen das Recht auf unverzügliche Einsichtnahme in die Patientenakte bzw. gegen Kostenerstattung Kopien davon zu erhalten.

90.6 Schweigepflicht

Markus Parzeller

Spitzen- und Leistungssportler stehen auch bei der ärztlichen Bewertung ihres Gesundheitszustands im Interesse der Öffentlichkeit. Plötzliche Erkrankungen, wie Depressionen, plötzlicher Leistungsabfall, Dopingvorwürfe, hohe Transfersummen oder Drogenkonsum, wecken ein öffentliches Informationsbedürfnis, das insbesondere bei medizinischen Hintergründen durch die Nachfrage bei den behandelnden Ärzten gestillt werden soll. Aufgrund seines Kapitals „Körper“ ist der **Profisportler** auf die besondere ärztliche Verschwiegenheit angewiesen und ohne Einwilligung dürfen beim Fehlen von Offenbarungsbefugnissen oder -pflichten keine ärztlichen Informationen herausgegeben werden.

Die ärztliche Schweigepflicht gilt als eine der höchsten ärztlichen Standes- und Rechtspflichten.

Praxisrelevante Regelungen zur ärztlichen Schweigepflicht finden sich u. a. im Strafrecht (§§ 203 ff. StGB), im Berufs- und Standesrecht (z. B. § 9 MBO, Landesberufsordnungen) und im Zivilrecht (Keding

et al. 2014, Parzeller und Bratzke 2000, Parzeller und Wenk 2004, Parzeller et al. 2005, Roebel et al. 2009, Parzeller 2012).

90.6.1 Rechtliche Grundlagen

Strafgesetzbuch § 203 StGB

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehörigen eines anderen Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert, (...) anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bestraft. (...)

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

Aus der Musterberufsordnung (in der Fassung des 118. Deutschen Ärztetages 2015 in Frankfurt): § 9 Schweigepflicht MBO; bitte rechtlich verbindliche Vorgaben in den Berufsordnungen der Landesärztekammern beachten

(1) Ärztinnen und Ärzte haben über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Ärztin oder Arzt anvertraut oder bekannt geworden ist – auch über den Tod der Patientin oder des Patienten hinaus – zu schweigen. Dazu gehören auch schriftliche Mitteilungen der Patientin oder des Patienten, Aufzeichnungen über Patientinnen und Patienten, Röntgenaufnahmen und sonstige Untersuchungsbefunde.

(2) Ärztinnen und Ärzte sind zur Offenbarung befugt, soweit sie von der Schweigepflicht entbunden worden sind oder soweit die Offenbarung zum Schutze eines höherwertigen Rechtsgutes erforderlich ist. Gesetzliche Aussage- und Anzeigepflichten bleiben unberührt. Soweit gesetzliche Vorschriften die Schweigepflicht der Ärztin oder des Arztes einschränken, soll die Ärztin oder der Arzt die Patientin oder den Patienten darüber unterrichten.

(3) Ärztinnen und Ärzte haben ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Personen, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der ärztlichen Tätigkeit teilnehmen, über die gesetzliche Pflicht zur Verschwiegenheit zu belehren und dies schriftlich festzuhalten.

(4) Wenn mehrere Ärztinnen und Ärzte gleichzeitig oder nacheinander dieselbe Patientin oder denselben Patienten untersuchen oder behandeln, so sind sie untereinander von der Schweigepflicht insoweit befreit, als das Einverständnis der Patientin oder des Patienten vorliegt oder anzunehmen ist.

90.6.2 Bruch der ärztlichen Schweigepflicht

Der Arzt ist jedoch nicht schrankenlos an die ärztliche Schweigepflicht gebunden. Die ärztliche Schweigepflicht kann beim Vorliegen von **Offenbarungsrechten und -pflichten** (Dettmeyer et al. 2010, Parzeller et al. 2005, Roebel et al. 2009, Parzeller 2012, Keding et al. 2014) durchbrochen werden und den Arzt zum Bruch der ärztlichen Schweigepflicht berechtigen oder sogar verpflichten (> Tab. 90.1).

Als eine **Offenbarungsbefugnis** lässt sich beispielhaft der **rechtfertigende Notstand** gemäß § 34 StGB oder die Informationsmöglichkeiten nach § 4 KKG aufführen, der die Rechtswidrigkeit des Bruchs der ärztlichen Schweigepflicht entfallen lässt. Ein

rechtfertigender Notstand wird nach feststehenden Regeln geprüft (Fischer 2015, Parzeller 2001, Parzeller et al. 2005, Parzeller 2012, Keding et al. 2014). Es muss eine **Konfliktsituation** vorliegen, in der eine gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr für eines der in § 34 StGB aufgelisteten Rechtsgüter besteht. Diese Gefahr muss durch den Bruch der ärztlichen Schweigepflicht bei Abwägung der widerstrebenden Interessen und einem Überwiegen des gefährdeten Rechtsguts abgewendet werden können und angemessen sein.

Als **Beispiel** lässt sich die Information der Führerscheinbehörden anführen, wenn ein aufgrund einer Erkrankung nicht zur Teilnahme am Straßenverkehr geeigneter, uneinsichtiger Patient entgegen ärztlichem Rat trotz umfassender Aufklärung und warnender Hinweise Auto fährt (BGH NJW 1968, 2.288 ff. Cave: Stufenabfolge beachten).

Im **sportärztlichen Bereich** kann sich eine Information an Dritte ergeben, wenn ein erkrankter, fahruntüchtiger und uneinsichtiger Sportler an einem Autorennen teilnehmen will und dadurch eine Gefahr für andere Sportler oder Zuschauer darstellt. In jedem Fall sollte der Bruch der ärztlichen Schweigepflicht **Ultima Ratio** sein.

Tab. 90.1 Ausgewählte Offenbarungsrechte und -pflichten zum Bruch der ärztlichen Schweigepflicht

Wichtige Offenbarungsrechte	Wichtige Offenbarungspflichten
• Entbindung von der Schweigepflicht (Einverständnis bzw. Einwilligung) • Stillschweigende Einwilligung im Rahmen der Sozialadäquanz (Information des weiter- bzw. nachbehandelnden Arztes; Information des Konsiliarius) • Mutmaßliche Einwilligung (bewusstloser Patient) • § 34 StGB bei Kindesmisshandlung, -missbrauch, Fremdgefährdung im Straßenverkehr • § 4 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz) • Eigene Geltendmachung von Honorarforderungen vor Gericht	• §§ 138 ff. StGB: Anzeige von geplanten schweren Straftaten • IfSG (Meldung bei meldepflichtigen Erkrankungen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten) • §§ 17 I S. 1 Nr. 3, 18 PStG: Anzeigepflicht von Geburten nach dem Personenstandsgesetz • Meldepflichten nach dem Sozialgesetzbuch

§ 34 StGB

Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstrebenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse das beeinträchtigte wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden.

Zum Schutz der Öffentlichkeit können sich Offenbarungspflichten beim Vorliegen **ansteckender Erkrankungen** ergeben (Infektionsschutzgesetz, IfSG). Die Pflicht zur Offenbarung geht dann als Spezialgesetz der ärztlichen Schweigepflicht vor.

Es besteht eine **namentliche Meldepflicht** für den Arzt gemäß §§ 8, 9 IfSG für den Krankheitsverdacht, die Erkrankung oder den Tod bei einem Katalog von Krankheiten (§ 6 IfSG) und bei dem direkten oder indirekten Nachweis sowie bei Hinweisen auf eine

akute Infektion bei den im Gesetz aufgeführten Krankheitserregern (§ 7 IfSG). Bei **Sportlern**, die in außereuropäischen oder tropischen Ländern aktiv waren, ist bei einer **Erkrankung zunächst unklarer Genese** auch an die Möglichkeit einer der in Deutschland seltener vorkommenden meldepflichtigen Erkrankungen zu denken.

LITERATUR

- Bergmann KO, Pauge B, Steinmeyer H-D (Hrsg.) (2012). *Gesamtes Medizinrecht*. Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden.
- Canale S (2005). Wrong-site surgery: A preventable complication. *Clin Orthop* 433: 26–29.
- Cowell H (1998). Wrong-site surgery. *J Bone Joint Surg* 80 A: 463.
- Dettmeyer R (2006). *Medizin & Recht für Ärzte*. 2. Aufl. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Dettmeyer R et al. (2010). Ausgewählte verfahrensrechtliche Aspekte bei Gewalt gegen Minderjährige. *Rechtsmedizin* 20: 200–210.
- DiGiovanni C, Kang L, Manuel J (2005). Patient compliance in avoiding wrong-site surgery. *J Bone Joint Surg* 85 A: 815–819.
- Dinkel M et al. (2014). *Medizin & Recht* (4): Doping im Sport und Strafrecht. *Via medici*. Online: www.thieme.de/via-medici/arzt-im-beruf-aerztliches-handeln-1561/a/medizin-und-recht-doping-im-sport-und-strafrecht-22427.htm (letzter Zugriff 20.4.2015).
- Eickhoff U, Fenger H (2004). *Chirurgie und Recht*. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Fischer T (2015). *Strafgesetzbuch und Nebengesetze*. 62. Aufl. Verlag C. H. Beck, München.
- Fleuth T et al. (2014). *Medizin & Recht* (6): Medizinische Behandlungsfehler. *Via medici*. Online: www.thieme.de/viamedici/arzt-im-beruf-aerztliches-handeln-1561/a/medizinische-behandlungsfehler-23539.htm (letzter Zugriff 20.4.2015).
- Hoffmann S et al. (2014). *Medizin & Recht* (2): Aufklärung und Einwilligung. *Via medici*. Online: www.thieme.de/viamedici/arzt-im-beruf-aerztliches-handeln-1561/a/medizin-und-recht-aufklaerung-und-einwilligung-21854.htm (letzter Zugriff 20.4.2015).
- Hofmann H-P (2008). Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport durch Fortentwicklung des Arzneimittelrechts. *PharmR* 11–17.
- Keding V et al. (2014). Schweigen ist Silber, Handeln ist Gold, *Medizin & Recht* (1): Ärztliche Schweigepflicht und Kinderschutz, *Via Medici*, 19: 26–28.
- Knaak J-P, Parzeller M (2014). Court decisions on medical malpractice. *Int J Legal Med* 128: 1049–1057.
- Laufs A, Uhlenbruck W (Hrsg.) (2010). *Handbuch des Arztrechts*. 4. Aufl. Verlag C. H. Beck, München.
- Laux J, Röbel A, Parzeller M (2012). Rechtsfragen zur ärztlichen Sterbehilfe Teil I – Terminologie und historischer Überblick. *Arch Kriminol* 230: 145–165.
- Laux J, Röbel A, Parzeller M (2013a). Rechtsfragen zur ärztlichen Sterbehilfe Teil II – Hilfe im Sterben, direkte aktive und indirekte aktive Sterbehilfe. *Arch Kriminol* 231: 1–32.
- Laux J, Röbel A, Parzeller M (2013b). Rechtsfragen zur ärztlichen Sterbehilfe Teil III – Passive Sterbehilfe, internationaler Rechtsvergleich, Fazit für die ärztliche Praxis. *Arch Kriminol* 231: 73–115.
- Leipold K (2006). Strafrechtliche Aspekte des Doping. *NJW-Spezial* 423–424.
- Martis R, Winkhart M (2014). *Arzthaftungsrecht Fallgruppenkommentar*. 4. Aufl. Schmidt-Verlag, Köln.
- Meinberg EG, Stern PJ (2003). Incidence of wrong-site surgery among hand surgeons. *J Bone Joint Surg* 85 A: 193–197.
- Neelmeier T (2014). Organisationsverschulden patientenfern Entscheider und einrichtungsbezogene Aufklärung. *Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden*.
- Parzeller M (2001). Die strafrechtliche Verantwortung des Arztes beim Doping. *Dt Z Sportmed* 52: 162–167.
- Parzeller M (2002a). Der Arzt als Beschuldigter in Arztstrafsachen: Die erste Vernehmung durch die Polizei. *Sport Orthop Traumatol* 18: 117–118.
- Parzeller M (2002b). Tödliche intrazerebrale Massenblutung nach Nierenarterien-PTA mit Stentimplantation unter der Gabe von Clopidogrel, ASS und Heparin i. v. *Nieren- und Hochdruckkrankheiten* 31: 409.
- Parzeller M (2003). Schmerzensgeld bei ärztlichen Behandlungsfehlern: Reform durch das 2. Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften. *Sport Orthop Traumatol* 19: 115–117.
- Parzeller M (2010). Verbotene Dopingstoffe – Transparente oder kryptische Regelungen im Arzneimittelgesetz? Teil I. *Stoffr*: 278–286.
- Parzeller M (2011a). Verbotene Dopingstoffe – Transparente oder kryptische Regelungen im Arzneimittelgesetz? Teil II. *Stoffr*: 26–40.
- Parzeller M (2011b). The punishment of gene doping – The relation between WADA prohibited lists, German Medicinal Products Act, German Doping Agents Amounts Ordinance, and Basic Law of the Federal Republic of Germany. *Drug Test Anal* 3: 688–694.
- Parzeller M (2011c). Rechtliche Aspekte des Dopings. In: Raschka C et al. (Hrsg.). *Doping – Klinik – Wirkstoffe – Methoden – Prävention*. Schattauer Verlag, Stuttgart. S. 31–48.
- Parzeller M (2012). Schweigepflicht als Teil des Persönlichkeitsschutzes in der Intensivmedizin. In: Salomon F (Hrsg.). *Praxisbuch – Ethik in der Intensivmedizin*. 2. Aufl. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin. S. 211–221.
- Parzeller M (2014). Das in 2007 reformierte Arzneimittelgesetz (AMG) – ein Erfolgsmodell im Kampf gegen Doping im Sport. *Dtsch Z Sportmed* 65: 279–288.
- Parzeller M, Bratzke H (2000). Grenzen der ärztlichen Schweigepflicht. *Dt Ärztebl* 97: A2.364–A2.370.
- Parzeller M, Bratzke H (2007). Verlust von Rechtsstaatlichkeit durch Abbau und Privatisierung rechtsmedizinischer Institute. In: *Institut für Kriminalwissenschaften und*

- Rechtsphilosophie Frankfurt a. M. (Hrsg.). Jenseits des rechtsstaatlichen Strafrechts. Peter Lang Verlag, Frankfurt. S. 177–202.
- Parzeller M, Centamore R (2008). Kampf gegen Doping im Sport – Gesetzliche Neuerungen. Rechtsmedizin 18: 189–194.
- Parzeller M, Prittwitz C (2009a). Statische oder dynamische Verweisung? Bedenkliche Unbestimmtheiten und Unklarheiten bei der Bestimmung der zu Dopingzwecken im Sport verbotenen Arzneimittel im Arzneimittelgesetz. Teil 1. StoffR 6: 101–110.
- Parzeller M, Prittwitz C (2009b). Statische oder dynamische Verweisung? Bedenkliche Unbestimmtheiten und Unklarheiten bei der Bestimmung der zu Dopingzwecken im Sport verbotenen Arzneimittel im Arzneimittelgesetz. Teil 2. StoffR 6: 119–125.
- Parzeller M, Rüdiger C (2007a). Doping im Sport: Wie sich Ärzte strafbar machen. Dtsch Arztebl 104: A 1.631–A 1.633.
- Parzeller M, Rüdiger C (2007b). Blutdoping: Unbestimmte Regelungen im Arzneimittelgesetz. ZRP 40: 137–140.
- Parzeller M, Wenk M (2004). Die ärztliche Schweigepflicht unter besonderer Berücksichtigung der ärztlichen Betreuung von Hochleistungs- und Profisportlern. Sport Orthop Traumatol 20: 187–194.
- Parzeller M, Zedler B (2011). Arztrecht und Verkehr – Ausgewählte medizinrechtliche Aspekte. In: Golka K et al. (Hrsg.) Verkehrsmedizin – Arbeitsmedizinische Aspekte. Ecomed, Landsberg. S. 285–300.
- Parzeller M, Zedler B (2013a). Das Patientenrechtegesetz (PatRG) – Teil 1: Gesetzgebungsverfahren, Behandlungsvertrag, Vertragspartner und deren Mitwirkungs- und Informationspflichten. Arch Kriminol 232: 73–90.
- Parzeller M, Zedler B (2013b). Das Patientenrechtegesetz (PatRG) – Teil 2: Einwilligung, Aufklärungspflichten, Dokumentation der Behandlung, Einsichtnahme in die Patientenakte. Arch Kriminol 232: 145–160.
- Parzeller M, Zedler B (2014). Das Patientenrechtegesetz (PatRG) – Teil 3: Beweislast in Haftungsfragen und kritisches Fazit. Arch Kriminol 233: 1–19.
- Parzeller M, Wenk M, Rothschild M (2005). Die ärztliche Schweigepflicht. Dt Arztebl 102: C224–C232.
- Parzeller M et al. (2008). Doping im Sport – Teil 2: Straf-, arzneimittel- und sportrechtliche Aspekte. StoffR 5: 206–222.
- Parzeller M et al. (2009). Aufklärung und Einwilligung des Patienten – Nach Maßgaben aktueller höchstrichterlicher und oberlandesgerichtlicher Rechtsprechung. Sonderbeilage des Deutschen Ärzteblatts. 29a – 291. www.aerzteblatt.de/archiv/64642/Aufklaerung-und-Einwilligung-des-Patienten-Nach-Massgaben-aktueller-hoechst-richterlicher-und-oberlandesgerichtlicher-Rechtsprechung?src=search (letzter Zugriff 4.6.2015).
- Parzeller M et al. (2009). Ausgewählte rechtliche Aspekte zu Doping im Sport im Kontext des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG). StoffR: 269–278.
- Parzeller M, Heise H, Rüdiger C (2010). Evaluierung der strafrechtlichen Bekämpfung des Dopings im Sport zwischen 2000–2007. StoffR: 39–52.
- Parzeller M, Prittwitz S, Prittwitz C (2013a). Doping und Dopingbekämpfung in der Bundesrepublik Deutschland Teil I: Situationsbeschreibung und Kurzdarstellung des Berichts der Bundesregierung zur Evaluation des Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport. StoffR: 67–76.
- Parzeller M, Prittwitz S, Prittwitz C (2013b). Doping und Dopingbekämpfung in der Bundesrepublik Deutschland Teil II: Kritische Diskussion des Berichts der Bundesregierung zur Evaluation des Gesetzes zur Verbesserung der Bekämpfung des Dopings im Sport (DBVG) und Fazit unter Berücksichtigung von weiteren gesellschaftlichen Formen des Dopings. StoffR: 109–119.
- Parzeller M et al. (2014). Pflicht zur Offenbarung von Behandlungsfehlern nach dem Patientenrechtegesetz. Rechtsmedizin 24: 263–271.
- Pauly J, Parzeller M (2004). Ärztliche Werbung: „Akquisition als solche ist nicht berufswidrig.“ Sport Orthop Traumatol 20: 255–260.
- Quaas M, Zuck R (2014). Medizinrecht. 3. Aufl. Verlag C. H. Beck, München.
- Raschka C, Zedler B, Parzeller M (2008). Doping im Sport – Teil 1: WADA- und NADA-Code, Verbotsliste und medizinische Aspekte. StoffR 5: 2–18.
- Ratzel R, Lippert H-D (2010). Kommentar zur Musterberufsordnung der deutschen Ärzte (MBO). 5. Aufl. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Ratzel R, Luxenburger B (Hrsg.) (2011). Handbuch Medizinrecht. 2. Aufl. Deutscher Anwalt Verlag, Bonn.
- Rieger H-J, Dahm F-J, Steinhilper K (Hrsg.) (2014). Heidelberger Kommentar – Arztrecht Krankenhausrecht Medizinrecht. Verlag C. F. Müller, Heidelberg.
- Ries H et al. (2004). Arztrecht – Praxishandbuch für Mediziner. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Roebel A, Wenk M, Parzeller M (2009). Die postmortale ärztliche Schweigepflicht. Rechtsmedizin 19: 35–50.
- Spickhoff A (Hrsg.) (2011). Medizinrecht. Verlag C. H. Beck, München.
- Spickhoff A (2013). Patientenrechte und Patientenpflichten – Die medizinische Behandlung als kodifizierter Vertragstypus. VersR 2013: 267–282.
- Steinbeck J, Fenger H (2004). Orthopädie und Recht. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.
- Striegel H, Vollkommer G (2001). Doping – Die Verantwortung des Sportarztes als Ansprechpartner für junge Leistungssportler. MedR: 112–117.
- Tolup N et al. (2014). Tod auf Rezept. Medizin & Recht. Teil 5: Sterbehilfe. Via Medici 19: 30–32.
- Ulsenheimer K (2015). Arztstrafrecht in der Praxis. 5. Aufl. Verlag C. F. Müller, Heidelberg.
- Wenzel F (Hrsg.) (2012). Der Arzthaftungsprozess – Medizinschaden Fehler – Folgen – Verfahren. Luchterhand-Verlag, Köln.
- Wienke A, Sailer R (2013). Aufklärung und Behandlung trotz Sprachbarriere – Wer trägt die Dolmetscherkosten? Hess Arztebl 846–847.

90.7 Grundlagen des Sportversicherungsrechts

Andrea Amerschläger

Der sportmedizinisch tätige Arzt sollte gerade beim Wettkampfsport auch über Grundzüge des Versicherungsrechts im Sport informiert sein.

Zu unterscheiden sind:

- **Sozialversicherungsverhältnisse**
 - gesetzliche Unfallversicherung, s. a. SGB (Sozialgesetzbuch) VII
 - gesetzliche Krankenversicherung, s. a. SGB V
 - gesetzliche Rentenversicherung, s. a. SGB VI
 - gesetzliche Arbeitslosenversicherung, s. a. SGB II
- **privatrechtliche Versicherungsverhältnisse.**

Die auch für den Sportmediziner interessanten Konstellationen werden anschließend kurz erörtert, um ihm als den Sportler betreuenden Arzt bzw. auch in seiner möglichen Funktion als medizinischer Sachverständiger und Gutachter einen kurzen Überblick zu verschaffen.

90.7.1 Versicherter Personenkreis

Die einzelnen **Sportvereine** haben zur privatrechtlichen Absicherung der Sportler im Allgemeinen über den jeweiligen Landessportbund entsprechende Sportversicherungen als **Gruppenversicherungsverträge** (Radek 1986). In diesen Gruppenversicherungsverträgen sind **juristische und natürliche Personen** versichert (Weber 2013). Im Streitfall gegen die Sportversicherung ist exakt zu klären, wer Versicherungsnehmer, Mitversicherter etc. ist, um die **Klagebefugnis** zu ermitteln und keine Klageabweisung wegen unzulässiger Ausübung eines fremden Rechts im eigenen Namen zu provozieren (OLG Köln, NJW-RR 2001, 532 f.).

Juristische Personen

Als juristischer Personenkreis im Rahmen der privatrechtlichen Sportversicherung sind neben gemeinnützigen Institutionen wie der Sporthilfe e.V. auch Landessportbünde, Sportfachverbände sowie

Sportverbände und -vereine auf Stadt-, Gemeinde- und Kreisebene zu nennen (Weber 2013). Diesen juristischen Personenkreis treffen insbesondere im Rahmen von Sportveranstaltungen Verkehrssicherungspflichten gegenüber den an der Veranstaltung teilnehmenden Sportlern sowie gegenüber Helfern, Zuschauern und Unbeteiligten. Zudem haftet der Veranstalter unter bestimmten Voraussetzungen für die Verkehrssicherheit von Sportgeräten, Sportstätten und Sportanlagen (Heermann 2008).

Natürliche Personen

Unter den Versicherungsschutz der Sportversicherung fallen alle **aktiven und passiven Sportler und Mitglieder** der Sportvereine. Ebenfalls erstreckt sich der Versicherungsschutz auf Trainer, Übungsleiter, Schieds- und Linienrichter, Funktionäre und für die Durchführung von versicherten Sportveranstaltungen beauftragte Hilfspersonen (Weber 2013). Bei **Berufssportlern** muss man unterscheiden, ob die Berufssportler als Beschäftigte einer nicht selbstständigen Tätigkeit ihren Sport im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ausüben. Dies ist dann der Fall, wenn eine Beschäftigung für eine Tätigkeit nach Weisung und Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers (§ 7 Abs. 1 SGB IV) besteht. Allerdings ist die Zahl der Berufssportler als abhängig Beschäftigte gering. Zumeist handelt es sich um Selbstständige, die ihre Leistung von Fall zu Fall oder mit eigenem Management selbst verwerten und aus diesem Grunde meist einem speziellen Versicherungsschutz unterliegen (Leube 2008).

90.7.2 Der Versicherungsfall

Für einen kurzen Überblick der Versicherungsfallkonstellationen wird nachfolgend nur auf den **einzelnen Sportler** und nicht auf Rechtsverhältnisse zwischen Versicherer und versicherter juristischer Person abgestellt. Weitergehende Informationen zu diesen Versicherungskonstellationen sind der angeführten ergänzenden Literatur zu entnehmen (Weber 2013).

Sportler im Sozialversicherungsrecht

Bei den Sozialversicherungen handelt es sich um **öffentlich-rechtliche** (Zwangs-)Zusammenschlüsse, die der Absicherung bestimmter Risiken dienen, denen das Mitglied dieses Zusammenschlusses, also der Bürger, ausgesetzt ist (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter etc.). Das Sozialversicherungssystem ist Ausdruck des Sozialstaats und des Solidarsystems. Es wird durch staatlich organisierte, öffentlich-rechtliche, selbst verwaltende Trägerschaft, den Zwangszusammenschluss, die Finanzierung durch die Mitglieder, die Leistung bei Mitgliedschaft etc. geprägt.

Sportler in der gesetzlichen Unfallversicherung **Sportveranstaltungen** in Betrieben stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung (Arbeitsunfall):

- bei betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen, auch unter Einbeziehung von Mitarbeitern, die nicht am Sport interessiert sind (Osing 2004, Keller 2005) oder
- bei – in der gesetzlichen Unfallversicherung versichertem – Betriebssport.

Um **Betriebssport** handelt es sich, wenn

- der Sport zum Ausgleich der betrieblichen Tätigkeit dient,
- der Wettkampfcharakter nebensächlich ist,
- die Tätigkeiten regelmäßig stattfinden,
- die Teilnehmer überwiegend dem Betrieb angehören und
- eine unternehmensbezogene, von der Unternehmensführung getragene Leitung und Organisation stattfindet (Reichert 2015).

Unfälle während einer reinen Freizeitgestaltung oder zur Befriedigung sportlicher oder kultureller Interessen der Beschäftigten, auch wenn diese im räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Betriebstätigkeit erfolgen und von dem Unternehmen gebilligt oder unterstützt werden (Bundessozialgericht, BSG, HVBG-INFO 2005, 355 ff.: Fußballturnier als nicht versicherte sportliche Gemeinschaftsveranstaltung), sind von diesem Schutzzweck **ausgenommen**.

Nach **Auffassung des BSG** sind im Rahmen der betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen oder des versicherten Betriebssports alle sportlichen Betätigungen mit spielerischem Charakter versichert,

wenn diese **zur Förderung des Gemeinsinns** oder des **Zusammengehörigkeitsgefühls aller Beschäftigten** dienen und nicht nur allein dem persönlichen Interesse des Betroffenen. Ein innerer Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und der zum Unfall führenden Verrichtung wurde beim Arbeitsunfall eines chirurgischen Assistenzarztes (Rotationstrauma im linken Kniegelenk und ein Trauma des rechten Kniegelenks) bei einem Fußballturnier einer Klinikette bejaht, da nach allen Voraussetzungen das Gericht eine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung mit Förderung der Kontakte zwischen den Mitarbeitern untereinander und zur Geschäftsleitung annahm (Thüringisches Landessozialgericht, LSG, Urt. v. 26.1.2005, Az: L1 U 404/02).

Bei **Fußballturnieren im Rahmen des Betriebsports** ist versicherungsrechtlich zu beachten, dass bei häufigen Veranstaltungen gegen andere Betriebsportgruppen der **Unternehmensbezug gesprengt** sein kann und somit ein erforderlicher innerer Zusammenhang für den gesetzlichen Unfallschutz entfallen kann (vgl. BSG, Urt. v. 26.10.2004, Az: B 2 U 38/03 R). Bei einer groß angelegten Gemeinschaftsveranstaltung – jährlicher Firmenlauf in Frankfurt, bei dem jährlich mehr als 50.000 Teilnehmer teilnehmen – hat das Landessozialgericht Hessen den Versicherungsschutz eines Teilnehmers abgelehnt. Als Begründung wurde angeführt, dass weder der Laufwettbewerb an sich noch die anschließende „Läufer-Party“ auf dem Firmengelände geeignet seien, die für eine betriebliche Gemeinschaft wesentliche Zielsetzung, nämlich Verbundenheit zwischen Unternehmensleitung und Beschäftigten sowie der Beschäftigten untereinander, zu erreichen, zumal beide Veranstaltungen nicht allen Betriebsangehörigen offen stehen (LSG Hessen NJW 2008, 2524).

Sportler in der gesetzlichen Krankenversicherung Sportler genießen, soweit sie der gesetzlichen Krankenversicherung als Pflichtversicherte oder freiwillig Versicherte angehören, einen gesetzlich festgelegten Versicherungsschutz. Diesen Versicherungsschutz müssen alle gesetzlichen Krankenkassen ihren Versicherten bieten. Für die Klärung von Streitigkeiten über Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung sind gemäß § 50 Sozialgerichtsgesetz (SGG) die Sozialgerichte zuständig (BSG VersR 1998, 486). Der **Gesetzgeber** gibt vor, welche

Leistungen zu erbringen sind, sodass die Krankenkassen **nur einen geringen Entscheidungsspielraum** haben.

Pflichtversichert sind die in § 5 SGB V genannten Personengruppen. § 6 SGB V führt die **Versicherungsfreiheit** aus, die bei Angestellten und Arbeitern ab einem bestimmten, gesetzlich normierten Jahreseinkommen eintreten kann und damit ein **Wahlrecht** zwischen einem freiwilligen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz ermöglicht.

Nach dem Grundsatz der gesetzlichen Krankenkassen hat jeder Versicherte einen Anspruch auf eine **grundlegende, medizinisch notwendige Versorgung** (§§ 11 ff. SGB V). **Vertragspartner** der gesetzlichen Krankenversicherungen sind zumeist Vertragsärzte. Dies bedeutet, dass dem Versicherten ggf. durch seine Krankenkasse Ärzte vorgegeben werden können. Eine Ergänzung zu dieser gesetzlichen Grundversorgung bietet eine **private Zusatzversicherung** für Sportler, in der z. B. die Versorgung durch den Chefarzt vereinbart ist. Auf die Chefarztbehandlung haben gesetzlich versicherte Patienten keinen Anspruch.

Des Weiteren sind die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung grundsätzlich **auf Deutschland begrenzt**. Insbesondere übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung nur teilweise die ärztlichen Kosten, die aufgrund eines Sportunfalls im europäischen Ausland entstehen. Kosten außerhalb der EU werden prinzipiell nicht übernommen.

Sportler im Privatversicherungsrecht

Um den Sportler auch noch weitergehend gegen Risiken abzusichern, die mitunter vom Solidarsystem des gesetzlichen Versicherungsschutzes nicht hinreichend oder gar nicht gedeckt werden, kann sich für den Sportler eine private Absicherung anbieten, wobei insbesondere für **Profisportler** darauf zu achten ist, dass eine **sorgfältige und umfassende Absicherung** vorgenommen wird.

Auch wenn im Privatrecht normalerweise der Grundsatz der Privatautonomie Geltung beansprucht, sind auch im Privatversicherungsrecht eine **Vielzahl von Fallkonstellationen und Ausgestaltungen** in den allgemeinen Versicherungsbedingungen und den Musterbedingungen zu den einzelnen

Versicherungskategorien kodifiziert. Das maßgebliche Gesetzeswerk, das Versicherungsvertragsgesetz (VVG), ist vom Gesetzgeber einer umfassenden Neubearbeitung unterzogen worden. Das **neue Recht** gilt für Versicherungsverträge **ab dem 1.1.2008**. Für Altverträge gilt es – mit Ausnahmen – ab dem 1.1.2009. Der Gesetzgeber räumt den Versicherungsunternehmen das Recht ein, mit dem neuen Recht nicht mehr konforme Klauseln in den Versicherungsbedingungen von Altverträgen mit Wirkung zum 1.1.2009 an das geänderte Gesetz anzupassen. Dieses Recht besteht nur bis zum 1.1.2009, kann also nach diesem Zeitpunkt nicht mehr ausgeübt werden. Erfolgt keine Umstellung, werden die mit dem neuen VVG nicht mehr konformen Klauseln ab dem 1.1.2009 unwirksam. An ihre Stelle tritt das Gesetz.

Sportler und Sport-Unfallversicherung

Die Unfallversicherung einer Sportversicherung soll den Versicherten gegen **finanzielle Folgen von Unfällen** absichern. Die Auslegung eines Unfalls nach den Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen sorgt immer wieder für rechtliche Streitigkeiten (Fritzweiler 2000, 2002).

Unfalldefinition

AUB 99 1.3.: Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet (vgl. auch fast ähnlicher Wortlaut AUB 88 § 1 III).

Nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts (OLG) München wurde als Unfall beim **Handball** anerkannt, dass der Handballspieler durch den stumpfen Hallenboden hängen blieb und sich dadurch den Fuß verdrehte und umknickte (OLG München, SpuRt 2001, 100).

Optischer Tod

Unter diesem versicherungsrechtlich relevanten Terminus *technicus* werden im Allgemeinen internistisch-neurologisch bedingte Todesfälle (z. B. Myokardinfarkt, zerebrale Blutung) gefasst, die den Tod als ein rein zufälliges, bei der Gelegenheit des Sports auftretendes, aber nicht durch den Sport verursachtes Ereignis betrachten (Parzeller und Raschka 1999).

Obwohl es sich beim sog. optischen Tod um keinen Unfall im Sinne von § 1 III AUB 88 handelt, da es an einer Einwirkung von außen fehlt, sind diese Fälle des tödlichen Zusammenbruchs während des Wettkampfs oder Trainings **in der Sportversicherung** (nicht in der reinen Unfallversicherung) **mitverschert**. Die Rolle des Sports für den Tod wird auch als Gelegenheitsursache beschrieben (Klotzbach und Püschel 2001).

In Abhängigkeit vom Alter des Verstorbenen, dessen Familienstand und der Anzahl seiner unterhaltsberechtigten Kinder werden die Versicherungsleistungen an die **Erben** gezahlt (Weber 2008). Bei Klärungen der Todesart und Todesursache kann eine **Obduktion** unerlässlich sein (Betz und Eisenmenger 1996, Klotzbach und Püschel 2001a, 2001b, Bratzke 2005), auch wenn der Sportversicherer gemäß § 9 VII d AUB 88 auf diese verzichtet hat (Weber 2013). Unabhängig von sportversicherungsrelevanten Fragestellungen können aber insbesondere **strafrechtliche Aspekte** (Doping) Anlass für eine Obduktion des Sportlers sein.

Unfalldefinition

AUB 99 1.4.: Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerzt oder zerrissen werden (vgl. auch fast ähnlicher Wortlaut AUB 88 § 1 IV).

Um als Sportler nach Verletzungen gemäß AUB 88 § 1 IV einen **Anspruch auf Leistungen geltend** machen zu können (z.B. Krankenhaustagegeld), muss die Verletzung durch eine **erhöhte Kraftanstrengung** hervorgerufen worden sein. Von einer solchen Kraftanstrengung ist auszugehen, wenn der mit einer normalen körperlichen Bewegung verbundene Kraftaufwand überschritten wird.

Teilweise wird von der Rechtsprechung vorausgesetzt, dass die **Körperkräfte** des Sportlers nicht nur zur Eigenbewegung, sondern auch zur Bewegung anderer Massen eingesetzt wurden (OLG Celle, VersR 1991, 1165: keine Anerkennung eines Bandscheibenvorfalles beim Aussteigen aus dem Flugzeug; OLG Düsseldorf, r + s 1999, 296 f.). Gegen diese Auffassung wendet sich jedoch das OLG Saarbrücken (NJW-RR 2002, 676 f.), das ein solches Erfordernis

der erhöhten Kraftanstrengung nicht entnimmt. Neben dem erhöhten Einsatz von Muskelkraft wird auf die individuelle **Konstitution** des Sportlers abgestellt (Weber 2013).

Je nach Bewegungs- und Verletzungsmuster und der ausgeübten Sportart wird von der Rechtsprechung geprüft, ob z.B. eine Achillessehnenruptur durch die geforderte erhöhte Kraftanstrengung hervorgerufen wurde oder nicht. Insbesondere die **Achillessehnenruptur beim Sport** hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen und gehört zu den häufigsten Sehnenrupturen (König et al. 1999). Unstreitig kann bei einer Ruptur von Unfallfolgen ausgegangen werden, wenn diese durch eine **traumatische Einwirkung**, z.B. durch den Tritt eines Gegners beim Fußballspiel, hervorgerufen wurde. **Verneint** wurde ein Achillessehnenriss als Unfall beim normalen Tennisspiel, da das Gericht anhand des geschilderten Sachverhalts weder aus dem Bewegungsablauf noch der Spielsituation eine Ausnahmesituation mit einer erhöhten Kraftanstrengung erkennen konnte (OLG Frankfurt, VersR 1994, 363).

Ein Riss der **Bizepssehnen** beim Sportkegeln wurde hingegen ebenso als erhöhte Kraftanstrengung gewertet (OLG Nürnberg, VersR 2000, 1490) wie das Zerreißen von Sehnen während des Fußballspiels (OLG Celle SpuRt 1996, 171). Auch der **Muskelfaserriss** eines Sportlehrers bei der Vorführung einer Kräftigungsübung durch Heben des Rumpfes bei Abstützung auf gestreckten Armen und Beinen wurde als Unfall infolge erhöhter Kraftanstrengung beurteilt (OLG Saarbrücken, NJW-RR 2002, 676 f.).

Wegen der versicherungsrechtlich schwierigen Problematik wird eine **histopathologische Untersuchung** des Sehnenmaterials vorgeschlagen (König et al. 1999). Der **sachverständige Rat** des qualifizierten Sportmediziners zum geschilderten Bewegungsablauf, der Konstitution des Sportlers, dem Verletzungsmuster etc. kann dem Gericht bei der Beurteilung einer erhöhten Kraftanstrengung hilfreich sein.

Sportler und Sport-Haftpflichtversicherung

Primär ist bei Haftpflichtfällen zwischen dem Haftungs- und dem Deckungsverhältnis zu differenzieren. Das **Haftungsverhältnis** bezeichnet das Verhältnis zwischen Schädiger und Geschädigtem. Das **Deckungsverhältnis** bezeichnet die Eintrittspflicht des Haftpflichtversicherers des schädigenden gegen-

über dem geschädigten Sportler. Im **Haftungsrecht** haben die Gerichte immer wieder über vom Sportler oder vom Veranstalter einer Sportveranstaltung verursachte Unfälle zu urteilen (Parzeller 2001, Fritzweiler 2000, 2002, 2004, 2006).

Eine Haftpflichtversicherung ist dann **eintrittspflichtig**, wenn dem geschädigten Sportler ein Anspruch aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmung privatrechtlichen Inhalts zusteht (AHB 02 § 1 I). Im Regelfall setzt diese Verpflichtung zum Schadensersatz ein **Verschulden** voraus (§ 823 Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Der **Versicherungsschutz** einer Haftpflichtversicherung erfasst alle Versicherungsfälle, die einen Personen- oder Sachschaden und unechte Vermögensschäden als Folge von Personen- oder Sachschäden zur Folge haben (Voit 2015).

Im Rahmen der **Haftungsfrage** bei Sportverletzungen ist zu klären, ob eine zivilrechtliche Haftung eintritt und ob dieses Risiko versicherbar ist. Es findet hierbei eine **Abwägung** zwischen der Eigenverantwortlichkeit des geschädigten Sportlers und der erforderlichen Sorgfaltspflicht der Mitspieler statt. Neben dem Gegenspieler können durch Sportler auch Zuschauer verletzt werden. In diesen Fällen kann sich auch noch eine Haftung zwischen Sportveranstalter und Zuschauer ergeben.

Grundsätzlich ist ein **schuldhafter Verstoß** im Sport gegen eine, dem Schutz eines anderen dienende Sorgfaltspflicht **schadensersatzpflichtig**. Von dieser Regel kann es jedoch bei den riskanteren Sportarten, z. B. Kampfsport und Wettkampfsportarten, eine **Ausnahme** geben. Hier führt die **Einhaltung der sportlichen Regeln** grundsätzlich zu einem **Haftungsausschluss** (OLG Karlsruhe, NJW 1978, 705; BGH NJW 1975, 109). Bei Wettkampf- und Mannschaftssportarten werden bei Einhaltung der Spiel- und Sportregeln Verletzungen durch den Gegner durch die Einwilligung des Verletzten oder auch als ein Handeln auf eigene Gefahr als gerechtfertigt angesehen (BGH, NJW 1966, 755; OLG Karlsruhe, NJW 1978, 705; Fleischer 1999).

Der BGH hat mit Urteil vom 5.11.1974 einen Schadensersatzanspruch eines Fußballspielers gegen seinen Gegenspieler abgewiesen. Der Kläger hatte Ansprüche wegen einer offenen Fraktur, die er beim Zweikampf erlitten hatte, geltend gemacht. Nach Auffassung des Gerichts, das nicht klären konnte, ob das Verhalten des Beklagten regelwidrig war, muss

ein Sportler **Verletzungen beim regelkonformen Spiel in Kauf nehmen** (Beweislast für den Regelverstoß beim Kläger). Eine Abwälzung des Haftungsrisikos auf den Gegner wurde vom BGH als widersprüchlich und Verstoß gegen den Grundsatz aus Treu und Glauben gemäß § 242 BGB gewertet (BGH, NJW 1975, 109; BGH VersR 1976, 591 ff.). Der BGH hat mit Urteil vom 29.1.2008 klargestellt, dass bei sportlichen Wettbewerben mit nicht unerheblichem Gefahrenpotenzial die Inanspruchnahme des schädigenden Wettbewerbers für ohne gewichtige Regelverletzungen verursachte Schäden eines Mitbewerbers nicht ausgeschlossen ist, soweit Versicherungsschutz bei einer Versicherungsgesellschaft besteht (BGH, VersR 2008, 540).

Eine **Haftungsfreistellung** ist bei nebeneinander betriebenen Individualsportarten (z. B. Tennissport) differenziert zu beurteilen (Scheffen 1990). Naturgemäß erfolgt hier kein Kontakt zur anderen Person. Daher muss der Maßstab der Verhaltensanforderung an den allgemeinen Grundsätzen gemessen werden. Zusammenfassend ist zur Haftungslage zu sagen, dass grundsätzlich **bei leichten Regelverstößen** eine Haftungsfreistellung anzunehmen ist.

Bei einem grob regelwidrigen Verhalten kann der Sportler in die Haftung kommen. Eine Haftung für die Zufügung einer Sportverletzung eines anderen ist gegeben, wenn ihm ein **schuldhafter Regelverstoß** zur Last fällt, der über eine geringfügige und häufige Regelwidrigkeit hinaus geht (LG Marburg, VersR 1989, 94). Insbesondere kann auch der einzelne Spieler gegenüber den **Zuschauern** haften, z. B. wenn er bei einem Eishockeyspiel einen Puck in den Zuschauerraum schlägt und dadurch einen Zuschauer verletzt (vgl. BGH VersR 1984, 164; Fleischer 1999).

Versicherungsschutz entsprechend den Versicherungsbedingungen besteht, wenn der Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsvertrag mitversicherte Person **von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch** genommen wird. Der Umfang des Versicherungsschutzes umfasst die Befreiung des Sportlers von Ansprüchen des Geschädigten (Freistellungs- und Befreiungsansprüche). Darüber hinaus sehen die Versicherungsbedingungen vor, dass der Versicherer begründete Schadensersatzansprüche des Geschädigten befriedigt und unbegründete Schadensersatzansprüche abwehrt (Glück 2014).

Dabei ist zunächst **unerheblich**, ob der geltend gemachte Anspruch begründet oder unbegründet ist. Der Versicherer muss für den Versicherungsnehmer in das Deckungsverhältnis eintreten, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Eigenschäden des Versicherungsnehmers bzw. des Sportlers sind nicht versichert.

Viele Versicherer verlangen vor Aufnahme einer riskanten Sportart eine **Anzeige wegen einer Gefahrerhöhung** nach §§ 23 ff. VVG. Unter der Erhöhung des Risikos ist die qualitative Veränderung einer versicherten Gefahr zu verstehen. Die Risikoerhöhung kann sich auf Personen oder Sachen beziehen. Insbesondere kann hier exakt die Ausübung einer „gefährlichen“ Sportart angegeben werden.

Zwar wird die Erhöhung mit einer **Prämienerhöhung** einhergehen; dafür übernimmt der Versicherer das Risiko im Eintritt eines Versicherungsfalles (Glück § 9 RN 42). Welche Sportarten als „gefährlich“ oder „besonders gefährlich“ zu gelten haben, ist jedoch insbesondere im Bereich der Entgeltfortzahlung und der Frage des Eigenverschuldens umstritten. Bisher wurden in der arbeitsrechtlichen Rechtsprechung nur **wenige Sportarten als besonders gefährlich** gewertet (Arbeitsgericht, ArbG, Hagen NZA 1990, 311: Kickboxen; AG München, SpuRt 1994, 204. Nicht dagegen: Landesarbeitsgericht, LAG, Rheinland-Pfalz SpuRt 2000, 115 ff.: Motorsport) (Schimke 1996).

Für einen Sportler können Schäden bei **Auslandsaufenthalt** brisant werden, da Versicherungsfälle im Ausland gemäß § 4 Ziffer 1 des 3. AHB ausgeschlossen sind. Der Sportler sollte darauf achten, dass hier eine **Zusatzversicherung** abgeschlossen wird.

Private Sport-Krankenversicherung

In der privaten Krankenversicherung schließt der Sportler einen privatrechtlichen Vertrag mit dem Versicherungsunternehmen. Streitigkeiten aus dem Versicherungsverhältnis fallen deshalb unter die Zuständigkeit der **Zivilgerichte**, § 13 GVG. Die private Versicherung kann lediglich als **Zusatzversicherung** zur gesetzlichen Versicherung, aber bei den erforderlichen Voraussetzungen auch als **Substitut** für die gesetzliche Krankenversicherung gewählt werden.

Bei einer substitutiven Krankenversicherung besteht seitens des Versicherers nicht die Möglichkeit zur ordentlichen **Kündigung** (Müller-Stein 2014). Der Sportler kann sich bei der privaten Versicherung die gewünschten Leistungen individuell aus der angebotenen Tarifpalette entsprechend seinen finanziellen Möglichkeiten auswählen. Insbesondere kann hier sowohl der Freizeit- als auch der Profisportler sein individuelles Versicherungspaket – zugeschnitten auf seine Bedürfnisse – bekommen. Möglicherweise legt der Sportler Wert auf eine Chefarzt-Behandlung oder er will bei einem Unfall in ein bestimmtes Krankenhaus gebracht werden.

Grundsätzlich bleibt die bei Abschluss des Vertrags gewählte Leistung für die Dauer der Laufzeit des Vertrags unverändert. Zugrunde liegen dem Versicherungsvertrag außer den Allgemeinen Versicherungsbedingungen und dem aktuellen Versicherungsschein die **Musterbedingungen für die Krankheitskosten- und Krankenhaustagegeldversicherung** (MBKK 94) und die **Tarifbedingungen**. Aufgrund der Reform des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) wird das private Krankenversicherungsrecht nicht grundlegend neu gestaltet. Allerdings sollen die Rechte der Versicherten verbessert werden. Beim Eintritt des Versicherungsfalles ergibt sich der genaue Umfang der Leistungspflicht nach wie vor aus den Versicherungsbedingungen und den Tarifbedingungen.

MBKK 94 § 1

- (1) Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle und andere im Vertrag genannte Ereignisse.
- (2) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen. Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Befund Behandlungsbedürftigkeit nicht mehr besteht. Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge ausgedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich zusammenhängt, so entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall. (...)

Der **Versicherungsfall** wird in der privaten Krankenversicherung definiert als die **medizinisch notwendige Heilbehandlung** einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen, in deren Verlauf Arbeitsunfähigkeit festgestellt wird (§ 12 MBKK 94).

Hier ist jedoch bei dem Merkmal der Notwendigkeit ein anderer Maßstab zu setzen als bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Eine Heilbehandlungsmaßnahme ist nach ständiger Rechtsprechung notwendig, wenn es nach den objektiven medizinischen Befunden und wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Behandlung vertretbar war, sie als medizinisch notwendig anzusehen. Dies ist dann der Fall, wenn eine **wissenschaftlich anerkannte Behandlungsmethode** zur Verfügung steht, die geeignet ist, die Krankheit zu heilen (BGH VersR 2003, 581).

Der Bundesgerichtshof hat damit klargestellt, dass mit der medizinisch notwendigen Heilbehandlung **keine Beschränkungen** der Leistungspflicht der Versicherer auf die **kostengünstigste Behandlung** möglich sind. Ein durchschnittlicher Versicherungsnehmer entnimmt dem Begriff der „medizinischen Notwendigkeit“ keine Kostengesichtspunkte („Alpha-Klinik-Urteil“). Lediglich beim Vorliegen zweier medizinisch gleichwertiger, kostenmäßig jedoch weit auseinander liegender Behandlungsmöglichkeiten ist der günstigeren Behandlung der Vorzug zu geben (OLG Köln VersR 1995, 1177; OLG Köln 1999, 302; Voit 2015). Eine **Begrenzung der Erstattungssätze** hat die ständige Rechtsprechung für die private Krankenversicherung **nicht für zulässig** erachtet (LG Hamburg, Urt. v. 10.8.2000, Az 302 S 69/99; LG Düsseldorf, Urt. v. 13.8.1999, Az 22 S 272/97; OLG Celle, Urt. v. 10.1.2000, Az 1 U 100/98). Ziel des § 192 Abs. 2 VVG n.F. ist es, die Rechtsprechung des BGH im Sinne der früheren Rechtsauffassung zu korrigieren. Der Versicherer ist dann nicht leistungspflichtig, wenn die getätigten Aufwendungen in einem „auffälligen Missverhältnis“ zu den erbrachten Leistungen stehen (Schimkowski und Höra 2008).

Des Weiteren ist hervorzuheben, dass bei der privaten Krankenversicherung eine **freie Wahl des Behandlers** garantiert ist. Für die behandelnden Ärzte bestimmt sich die Höhe der Vergütung nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ; Müller-Stein 2014). Die private Krankenversicherung umfasst automatisch eine **europaweite**, oft auch eine weltweite Kostenerstattung.

Rechtsschutzversicherung für den Sport

Eine Rechtsschutzversicherung kann für den Sportler sinnvoll sein, wenn er das Kostenrisiko (Gerichts- und Anwaltskosten) im Zivil- und/oder Strafverfahren (keine aktive Strafverfolgung) minimieren will.

Exemplarisch lassen sich anführen:

- Schadensersatz-Rechtsschutz für den Motorsport
- Strafrechtsschutz bei Sportarten mit erheblichem Verletzungsrisiko
- Arbeits-Rechtsschutz
- Sozialgerichts-Rechtsschutz
- Vertrags-Rechtsschutz (Weber 2013)

Zusatzversicherung

Zur weiteren Absicherung kann sich eine **private Berufsunfähigkeitsversicherung** für den Sportler empfehlen, da die gesetzliche Erwerbsminderungsrente (SGB 6 § 37 ff.) keinen adäquaten finanziellen Schutz mehr bietet. In der gesetzlichen Berufsunfähigkeitsversicherung besteht der Schutz nur, wenn weniger als 3 Stunden tägliche Arbeit in irgendeinem Beruf nicht mehr möglich sind (Regelung für nach dem 1.1.1961 Geborene). Sollte der Sportler aufgrund einer Sportverletzung berufsunfähig (unabhängig von dem Verschulden Dritter) werden, tritt die Berufsunfähigkeitsversicherung ein. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer während der Dauer der Versicherung berufsunfähig wird (BGH VersR 1993, 469).

Die sozialversicherungsrechtliche Berufsunfähigkeit ist mit der privaten Berufsunfähigkeit nicht inhaltsgleich. Die private Berufsunfähigkeit kann im Allgemeinen **nicht auf Ersatzberufe** verweisen, die nichts mit der ursprünglichen Tätigkeit des Versicherungsnehmers gemein haben.

Bei vielen Sportarten – insbesondere im **Profibereich** – geht es um gravierende Gehalts- und Transferzahlungen sowie lukrative Sponsorenverträge. Zur Abwendung des wirtschaftlichen Risikos bei Sportunfähigkeit kann eine **Sportunfähigkeitsversicherung** (spezielle Berufsunfähigkeitsversicherung für Sportler) sinnvoll sein, die beim verletzungsbedingten Ende der sportlichen Laufbahn die finanzielle Zukunft des Sportlers absichert.

Als Zusatzversicherungen kommen **Kfz-Zusatzversicherungen** in Frage, die z. B. Schäden bei Fahrzeugen abdecken, die Spielerbetreuer auf Fahrten zu

den Spielen (vgl. OLG Düsseldorf, NJW-RR 2004, 970 f.; OLG Düsseldorf NJWE-VHR 1996, 157 f.) oder beim Transport von Sportgeräten (AG Düsseldorf, NJWE-VHR 1998, 35: Transport eines Segelboots zur Regatta) erleiden. **Keinen Versicherungsschutz** genießen hingegen **freiwillige Fahrten** von privaten Helfern, die nicht vom Verein beauftragt wurden oder die einem Zuschauer gleichzustellen sind (OLG Köln, NVersZ 2001, 475 f.).

Bei umfangreicher Reisetätigkeit, insbesondere Auslandsreisen des Sportlers, kann sich eine **Reisegepäckversicherung** als nützlich erweisen. Diese Reisegepäckversicherung schützt den Sportler vor Verlust oder Beschädigungen des Reisegepäckes. Als **Reisegepäck** gelten nach der Legaldefinition des § 1 AVBR 92 „sämtliche Sachen des persönlichen Bedarfs, die während einer Reise mitgeführt, am Körper, in der Kleidung getragen oder durch ein übliches Transportmittel befördert werden“. Der Versicherungsschutz besteht während der Dauer der Reise. Er beginnt mit der Entfernung des Reisegepäckes aus der Wohnung und endet mit dem Wiederbetreten (AG Potsdam, VersR 2002, 1554; Knappmann 2015). **Sportgeräte mit Zubehör** (z. B. Skier mit Stöcken) sind ebenfalls versichert, wenn sie auf der Reise mitgeführt werden (§ 1 Nr. 3 AVBR 92).

Nicht versichert sind in der Regel **Luft- und Wasserfahrzeuge** (§ 1 Nr. 3 AVBR 92). Als Luftfahrzeuge gelten auch die zu sportlichen Zwecken mitgeführten Gleitschirme und Flugdrachen (OLG München VersR 1994, 344). Hier ist es jedoch möglich, eine auf das **Sportgerät zugeschnittene Reisegepäckversicherung** abzuschließen.

LITERATUR

- Betz P, Eisenmenger W (1996). Der Tod am Arbeitsplatz. Vers Med 48: 2.
- Bratzke H (2005). Leserbrief zu: Kardinale Zwischenfälle im Sport. Dtsch Z Sportmed 56: 341.
- Fleischer H (1999). Reichweite und Grenzen der Risikoübernahme im in- und ausländischen Sportrecht. VersR 785.
- Fritzweiler J (2000). Neueste Rechtsprechung zum Sportrecht. NJW 997–1000.
- Fritzweiler J (2002). Neueste Rechtsprechung zum Sportrecht in den Jahren 1999–2001. NJW 1014–1017.
- Fritzweiler J (2004). Neueste Rechtsprechung zum Sportrecht in den Jahren 2002–2003. NJW 989–993.
- Fritzweiler J (2006). Neueste Rechtsprechung zum Sportrecht in den Jahren 2004–2005. NJW 960–966.
- Glück S (2014). Allgemeine Haftpflichtversicherung. In: Bühren van H (Hrsg.). Handbuch des Versicherungsrechts. 6. Aufl. Deutscher Anwaltsverlag, Köln.
- Heermann P (2008). Zivilrechtliche Haftung beim Zugspitz-Extremberglauf? NJW XIV-XVI.
- Keller W (2005). Arbeitsunfall bei betrieblichem Fußballturnier. Anm. zu BSG 2. Senat, Urt. v. 26.10.2004, B 2 U 16/04 R. juris-PR Soz R v.19.5.2005.
- Klotzbach H, Püschel K (2001a). Verdeckte und scheinbare Unfalltodesfälle (I). Vers Med 109.
- Klotzbach H, Püschel K (2001b). Verdeckte und scheinbare Unfalltodesfälle (II). Vers Med 159.
- König P et al. (1999). Versicherungsrechtliche Beurteilung der traumatischen Achillessehnenruptur. Vers Med 80.
- Knappmann U (2015). Unfallversicherung. In: Prölss J, Martin A (Hrsg.). Versicherungsvertragsgesetz. 29. Aufl. Verlag C. H. Beck, München.
- Leube K (2008). Haftungsbeschränkungen bei Arbeitsunfällen im Berufssport. VersR 880–883.
- Müller-Stein R (2014). Krankenversicherung. In: Bühren van H (Hrsg.) Handbuch des Versicherungsrechts. 6. Aufl. Deutscher Anwaltsverlag, Köln.
- Osing S (2004). Unfallversicherung bei betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen. Anm. zu BSG 2. Senat, Urt. v. 9.12.2003, B 2 U 52/02 R. juris-PR Soz R v. 8.4.2004.
- Parzeller M (2001). Die Haftung zwischen Sportlern für untereinander zugefügte Sportverletzungen. Sport Orthop Traumatol 17: 98–99.
- Parzeller M, Raschka C (1999). Der plötzliche und unerwartete Tod im Vereinssport der Bundesländer Berlin und Brandenburg (Januar 1992–April 1997). Vers Med 51: 157–160.
- Prölss J (2015). AVBR. In: Prölss J, Martin A (Hrsg.). Versicherungsvertragsgesetz. 29. Aufl. Verlag C. H. Beck, München.
- Radek E (1986). Versicherungsschutz beim Sport. NZA: 414–416.
- Reichert B (2015). Handbuch des Vereins- und Verbandrechts. 13. Aufl. Luchterhand-Verlag, Neuwied München.
- Scheffen E (1990). Zivilrechtliche Haftung im Sport. NJW 2658–2665.
- Schimikowski P, Höra K (2008). Das neue Versicherungsvertragsgesetz. Bundesanzeiger Verlag, Köln.
- Schimke M (1996). Sportrecht. Verlag Fischer/Heymanns, Köln Frankfurt.
- Voit W (2015). Krankenversicherung. In: Prölss J, Martin A (Hrsg.). Versicherungsvertragsgesetz. 29. Aufl. Verlag C. H. Beck, München.
- Weber W (2013). Sportversicherung. In: Terbille M, Höra K (Hrsg.). Münchener Anwaltsbandbuch Versicherungsrecht. 3. Aufl. Verlag C. H. Beck, München.